

GUILHERME FRANCISCO SOUZA AMARAL | IZABELA SEDLMAIER SOUZA | LARISSA DE PAULA X. DE FIGUEIREDO
MARCELA FRANCE ZAIDMAN | NAYENE LUDMILA GONÇALVES SELLERA | ROGERIO NEVES



JULGADOS COMENTADOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR





JULGADOS COMENTADOS DE

DIREITO DO CONSUMIDOR

As relações consumeristas são, em razão de sua natureza, provavelmente o tipo de relação jurídica mais constantemente praticada no dia-a-dia dos núcleos urbanos. Como consequência, a jurisprudência dos tribunais superiores relativa a essa seara é, em termos quantitativos e qualitativos, das mais ricas e singulares dentro dos ramos do conhecimento jurídico. O objetivo do presente trabalho é trazer à tona alguns dos principais e mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, comentando-os segundo a análise doutrinária e explorando as diversas maneiras pelas quais esses enunciados jurisprudenciais terminam por transformar, emendar e até contrariar nossa noção sobre os elementos jurídicos inerentes aos diversos tipos de contratos de consumo.

ISBN 9786589904021



9 786589 904021 >



EXPERT
EDITORA DIGITAL

 **creative commons**

Julgados Comentados de Direito do Consumidor

Julgados Comentados de Direito do Consumidor

Autores

Guilherme Francisco Souza Amaral

Izabela Sedlmaier Souza

Larissa de Paula Xavier de Figueiredo

Marcela France Zaidman

Nayene Ludmila Gonçalves Sellera

Rogério de Cássio Neves Ferreira Filho

Belo Horizonte, 2021

Direção editorial: Luciana de Castro Bastos
Diagramação e Capa: Daniel Carvalho e Igor Carvalho
Revisão: Do autor

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.



Todos os livros publicados pela Expert Editora Digital estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 BY-SA. <https://br.creativecommons.org/>

"A prerrogativa da licença creative commons 4.0, referencias, bem como a obra, são de responsabilidade exclusiva do autor"

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AMARAL, Guilherme Francisco Souza, SOUZA Izabela Sedlmaier, FIGUEIREDO, Larissa de Paula Xavier de, ZAIDMAN Marcela France, SELLERA Nayene Ludmila Gonçalves, FILHO, Rogério de Cássio Neves Ferreira.

Julgados Comentados de Direito do Consumidor.

Belo Horizonte, 2021: Editora Expert.

Autores: Guilherme Francisco Souza Amaral, Izabela Sedlmaier Souza, Larissa de Paula Xavier de Figueiredo, Marcela France Zaidman, Nayene Ludmila Gonçalves Sellera, Rogério de Cássio Neves Ferreira Filho.

ISBN: 978-65-89904-02-1

1. Código de Defesa do Consumidor 2. Direito 3. I. I. Título

CDD:341.37

Pedidos dessa obra:

experteditora.com.br
contato@editoraexpert.com.br





Dr. Eduardo Goulart Pimenta

Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e PUC/MG

Dr. Rodrigo Almeida Magalhães

Professor Associado da Faculdade de Direito da UFMG e PUC/MG

Dr. João Bosco Leopoldino da Fonseca

Professor Titular da Faculdade de Direito da UFMG

Dr. Marcelo Andrade Féres

Professor Associado da Faculdade de Direito da UFMG

Sumário

CAPÍTULO: 1

Guilherme Francisco Souza Amaral

O fortuito externo e interno nos serviços de estacionamento

Resumo:	10
1. Introdução.....	11
2. Da caracterização da relação de consumo	11
3. Da responsabilidade objetiva do prestador de serviços.	15
3.1. Do afastamento da responsabilidade objetiva	19
3.1.1 Do caso fortuito e da força maior	22
4. Da jurisprudência do STJ	25
4.1. Dos roubos em estacionamentos	27
4.2 Do <i>vallet parking</i>	36
4.3 Dos locais mantidos pela Administração Pública	39
5. Conclusão.....	45
6. Referências.....	46

CAPÍTULO: 2

Izabela Sedlmaier Souza

Inaplicabilidade do CDC ao contrato de conta-corrente entre corretora de *bitcoin* e instituição financeira

Resumo:	51
1. Introdução.....	52
2. Caso concreto: disputa entre corretora de <i>bitcoin</i> e instituição financeira	53
3. Conceito de consumidor.....	55
3.1. Consumidor <i>standard/stricto sensu</i>	56
3.2 Consumidor equiparado	65
4. Descaracterização da corretora de <i>bitcoin</i> como consumidora e acerto da decisão do STJ.....	66
5. Conclusão.....	70
6. Referências.....	71

CAPÍTULO: 3

Larissa de Paula Xavier de Figueiredo

A cobrança de uma “taxa de conveniência” pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet

Resumo:	74
1. Introdução.....	74
2. Das práticas comerciais.....	75
3. Informativo 644 STJ - Da proibição de cobrança da taxa de conveniência pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet	80
4. Informativo 683 STJ - Da licitude a cobrança de uma “taxa de conveniência” pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet	82
5. Conclusão.....	83
6. Referências.....	84

CAPÍTULO: 4

Marcela France Zaidman

Operadora de plano de saúde e custeio de acompanhante de paciente idoso na internação hospitalar

Resumo:	86
1. Introdução.....	87
2. A proteção do idoso na seara internacional.....	88
3. A proteção do idoso no direito interno.....	90
4. A proteção do idoso segundo o Código de Defesa do Consumidor.. ..	92
5. A figura do acompanhante do paciente idoso na legislação nacional.....	96
6. Conclusão.....	98
7. Referências.....	99

CAPÍTULO: 5

Nayene Ludmila Gonçalves Sellera

Plano de saúde e responsabilidade solidária por danos causados pelos médicos e hospitais próprios ou credenciados

Resumo:	103
1. Introdução.....	104
2. Plano de saúde - conceito e relação consumerista	105
3. Caso concreto	108
4. Conclusão.....	116
5. Referências.....	119

CAPÍTULO: 6

Rogério de Cássio Neves Ferreira Filho

A responsabilidade objetiva em face da ausência de prévia informação

Resumo:	122
1. Introdução.....	122
2. Da responsabilidade objetiva no CDC	124
3. Direito a informação	126
4. Da teoria do risco do desenvolvimento	129
5. Caso concreto	131
6. Conclusão.....	136
7. Referências.....	137

CAPÍTULO 1

O fortuito externo e interno nos serviços de estacionamento

Guilherme Francisco Souza Amaral¹

Resumo:

O presente trabalho analisará a possibilidade de exclusão da responsabilidade do prestador de serviços de estacionamento em razão de danos ocorridos ao seu consumidor por aplicação da teoria do fortuito externo. Será visto que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, como via de regra, a responsabilidade objetiva do fornecedor, seja ele um fornecedor de produtos ou um prestador de serviços. Demonstrar-se-á que, para se eximir da obrigação de reparar um dano, o fornecedor apenas pode se valer de excludentes limitadas que recaiam sobre a exclusão do dano, da conduta ou do nexo de causalidade. Dentro das excludentes do nexo causal, encontram-se o caso fortuito e a força maior. Relativamente às relações de consumo, a doutrina diferencia o fortuito interno e o fortuito externo. O primeiro não serviria à exclusão da responsabilidade do prestador, e o segundo sim. Após a explicação desses conceitos, será demonstrado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acaba por elucidar de que forma são aplicáveis no que tange aos tipos de serviços de estacionamento. Concluir-se-á que a caracterização do que é fortuito externo varia segundo o tipo de acontecimento (dano, furto ou roubo), bem como à maneira pela qual o serviço é realizado.

Palavras-chave: Responsabilidade do prestador de serviços. Fortuito interno. Fortuito externo. Serviço de estacionamento.

¹ Pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Damásio, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), advogado.

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar possibilidade de exclusão da responsabilidade do prestador de serviços de estacionamento pela exclusão do nexo causal por ocorrência de caso “fortuito externo”.

Para tanto, primeiramente, será identificado o serviço de estacionamento como uma relação de consumo, expondo os elementos que a constituem. Após, serão expostas as espécies de responsabilidade cível dos prestadores de serviço, identificando-se à qual pertence a do prestador de serviços dessa natureza.

Adiante, serão esmiuçadas as possibilidades legais e extralegais de exclusão da responsabilidade do fornecedor, entre elas o fortuito externo.

Por fim, será analisada a maneira pela qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou os preceitos expostos aos casos concretos. Destaca-se que o tema possui notória importância, tendo em vista que o serviço objeto do trabalho é usualmente presente em núcleos urbanos e que a problemática inerente aos danos ocorridos durante sua prestação é contumaz na vida cotidiana, o que se exemplifica pelo elevado número de julgados existente no STJ.

2. Da caracterização da relação de consumo

Em primeiro plano, cabe identificar qual legislação, em regra, é aplicável ao serviço de estacionamento. Para tanto, basta identificar se é prestado de forma a caracterizar relação de consumo, caso em que se aplicará o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, os primeiros dispositivos legais do CDC elucidam quais são os elementos que constituem uma relação de consumo:

Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (BRASIL, 1990).

Nota-se que são elementos subjetivos, fornecedor e consumidor, e objetivos, produto e serviço. Do texto legal, extrai-se que há duas espécies de fornecedor (fornecedor *lato sensu*): o fornecedor de produtos (fornecedor *strictu sensu*) e o prestador de serviços.

Nesse sentido, explica Tartuce: “a palavra fornecedor está em sentido amplo, a englobar o fornecedor de produtos – em sentido estrito – e o prestador de serviços” (TARTUCE, 2016, p. 71).

O *caput* do art. 3º deixa evidente que o fornecedor (*lato sensu*) pode ser pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Ademais, a lei não estabelece a intenção de lucro como requisito essencial à caracterização. Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um entre despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos, sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração. (BRASIL, 2004).

Segundo a doutrina, requisito implícito é a habitualidade do exercício da atividade. Assim, aquele que não possui a pretensão de prestar o serviço com certa perenidade não pode ser considerado fornecedor, excluindo-se quem o faz de forma eventual ou esporádica.

Nas palavras de Tartuce: “a par dessa construção, se alguém atuar de forma isolada, em um ato único, não poderá se enquadrar como fornecedor ou prestador, como na hipótese de quem vende bens pela primeira vez, ou esporadicamente, com ou sem o intuito concreto de lucro” (TARTUCE, 2016, p. 72).

No que tange ao consumidor, cabe destacar que característica intrínseca à sua existência é a presença de uma vulnerabilidade em face ao fornecedor. Trata-se do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, previsto no inciso I do art. 4º do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
[...] (BRASIL, 1990).

Em verdade, o referido princípio consiste em uma constatação fática de que as relações de consumo, ao contrário das demais, não ocorrem mediante uma construção harmônica da relação jurídica, mas sim por meio de um mercado massificado de propostas predefinidas por parte de fornecedores. Por isso, a vulnerabilidade do consumidor decorre da sua essência, e não pode ser questionada ou afastada judicialmente, caracterizando presunção *jure et de jure*.

Nas palavras de TARTUCE (2016):

Todo consumidor é sempre vulnerável, característica intrínseca à própria condição de destinatário final do produto ou serviço [...]. Assim, enquadrando-se a pessoa como consumidora, fará jus aos benefícios previstos nesse importante estatuto jurídico protetivo. Assim, pode-se dizer que a vulnerabilidade é elemento posto da relação de consumo e não um elemento pressuposto, em regra. (TARTUCE, 2016, p. 42).

Após essa exposição, faz-se possível concluir que, via de regra, aquele que presta serviço de estacionamento o faz na condição de prestador de serviços (fornecedor em sentido amplo). Isso porque o

faz por meio do oferecimento unilateral e padronizado de um serviço com habitualidade.

Ademais, é evidente a vulnerabilidade do cliente face ao prestador do serviço, uma vez que as condições relativas à sua execução já são previamente determinadas pelo prestador, de modo que sua autonomia é consideravelmente reduzida ou inexistente. Por fim, ressalta-se que pouco importa se o estacionamento é gratuito ou não, público ou privado, pois, tal como exposto, nenhum desses elementos é essencial à caracterização da relação de consumo.

Isso posto, analisar-se-á as regras por meio das quais, identificada uma relação de consumo, é regulada a responsabilidade do prestador de serviços.

3. Da responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

O caput do art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos causados em decorrência da atividade consumerista é de natureza objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa ou dolo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (BRASIL, 1990).

Destaca-se que o art. 17 do CDC equipara, para fins de responsabilidade civil, à condição de consumidor aquele que, mesmo não sendo consumidor direto da relação, sofre dano em sua esfera jurídica: “art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos

consumidores todas as vítimas do evento” (BRASIL, 1990).

Segundo a doutrina, isso representa a adoção pelo CDC da figura do *bystander*. Assim, explica Tartuce:

Como exaustivamente demonstrado no capítulo anterior, o CDC amplia substancialmente o conceito de consumidor, ao consagrar o enquadramento do consumidor equiparado, por equiparação ou *bystander*. Consagra o art. 17 da Lei 8.078/1990 que todos os prejudicados pelo evento de consumo, ou seja, todas as vítimas, mesmo não tendo relação direta de consumo com o prestador ou fornecedor, podem ingressar com ação fundada no Código de Defesa do Consumidor, visando a responsabilização objetiva do agente causador do dano. (TARTUCE, 2016, p. 156).

Percebe-se, ainda, que a responsabilidade do prestador de serviços é solidária dentro da cadeia de prestação do serviço. Isso significa que, além de ser irrelevante para o consumidor se o dano foi de responsabilidade ou não do fornecedor, também lhe é indiferente qual dos fornecedores ou de seus prepostos dentro dessa cadeia foi o autor da conduta danosa. Nas palavras de Tartuce:

Como demonstrado exaustivamente no presente estudo, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores. Tal opção visa a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça. Desse modo, não tem o consumidor o

ônus de comprovar a culpa dos réus nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços. (TARTUCE, 2016, p. 120).

Há, contudo, exceções previstas na lei. Nesse sentido, o art. 13 do CDC estabelece regras distintas no que tange ao comerciante de produtos:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. (BRASIL, 1990).

Nota-se que a responsabilidade do comerciante não é solidária nem, via de regra, objetiva. Conforme o inciso III, o comerciante apenas pode ser acessado, diretamente, se à título de culpa (responsabilidade subjetiva), por meio de comprovação da não conservação adequada do produto (seja por dolo ou culpa). Para que seja objetivamente responsabilizado (incisos I e II), faz-se necessário que a identificação dos fornecedores anteriores da cadeia de produtos ou de serviços (fabricante, construtor, produtor, importador, construtor) não seja possível.

Por outro lado, o §4º do art. 14 também excepciona o regulamento

da responsabilidade dos profissionais liberais:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (BRASIL, 1990).

Assim, a responsabilidade dos profissionais liberais é de natureza subjetiva. A lei, contudo, não conceitua o que seria um profissional liberal. Segundo Nunes, são quatro os elementos: “a) autonomia profissional, sem subordinação; b) prestação pessoal dos serviços; c) elaboração de regras pessoais de atendimento; d) atuação lícita e eticamente admitida” (NUNES, 2007. p. 230-231).

Essa escolha pelo legislador advém do fato de, usualmente, os profissionais liberais, diferentemente dos demais fornecedores, não exercerem trabalhos massificados nem concentrados em contratos de adesão. Por isso, normalmente, não existe vulnerabilidade maior do consumidor em face do profissional liberal que justifique a aplicação da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, esclarece Tartuce:

A norma é justificada, visto que os profissionais liberais individuais, assim como os consumidores, estão muitas vezes em posição de vulnerabilidade ou hipossuficiência [...]. Desse modo, a título de exemplo, a responsabilidade pessoal de advogados, dentistas e médicos somente existe no âmbito

consumerista se provada a sua culpa, ou seja, o seu dolo – intenção de causar prejuízo – ou a sua culpa, por imprudência (falta de cuidado + ação), negligência (falta de cuidado + omissão) ou imperícia (falta de qualificação geral para desempenho de uma atribuição). (TARTUCE, 2016, p. 121).

Notoriamente, os prestadores serviço de estacionamento, via de regra, não o fazem na condição de profissionais liberais, uma vez que não prestam o serviço de forma pessoal, mas sim por meio de uma estrutura massificada e padronizada aos seus clientes.

Conclui-se, então, que o prestador de serviços de estacionamentos, uma vez que não é comerciante de produtos nem profissional liberal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores. Cabe agora esmiuçar quais as hipóteses legais que permitem o afastamento dessa responsabilidade.

3.1. Do afastamento da responsabilidade objetiva

A compreensão da exclusão de uma responsabilidade objetiva fica mais didática com a exposição dos seus elementos. Segundo Diniz, a responsabilidade cível objetiva possui três elementos:

- a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco;
- b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima;
- c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. (DINIZ, 2005, p. 42).

Ausente qualquer um deles, inexistirá responsabilidade a ser imputada. Diz-se objetiva justamente porque seu aspecto subjetivo (conduta por meio de dolo ou por meio de culpa) não é relevante para sua caracterização, fator que a distingue da responsabilidade subjetiva. Isso posto, sempre que algum dos seus elementos (conduta, dano e nexo causal) não ocorrer, será ela afastada.

Nesse sentido, o §3º do art. 14 aborda hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do prestador de serviços:

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...] (BRASIL, 1990).

Verifica-se que o código exclui a responsabilidade objetiva pela inexistência de defeito (art. 14, §3º, I). Trata-se de exclusão por ausência do elemento “dano”. Em outros termos: se o serviço não possui nenhum defeito, não há possibilidade de que tenha causado danos e, por isso, não há responsabilidade.

Nesse sentido, esclarece Tartuce:

Como primeira excludente, a lei menciona a não colocação do produto no mercado (art. 12, § 3º, I) e a ausência de defeito no produto ou no serviço (art. 12, § 3º, II e art. 14, § 3º, I). Em suma, não haverá dever de indenizar por parte dos fornecedores e prestadores se não houver dano reparável. Como é notório, ausente o dano, ausente a responsabilidade civil, dedução que pode ser retirada, entre outros, do art. 927, caput, do CC/2002. A verdade é que

a ausência de dano não constitui excludente de responsabilidade civil, mas falta de um de seus pressupostos, pecando o legislador consumerista por falta de melhor técnica nesse aspecto. De toda sorte, cabe alertar que cresce na doutrina e na jurisprudência nacionais a adoção da teoria da responsabilidade civil sem dano, conforme será aprofundado mais à frente. (TARTUCE, 2016, p. 164).

Por outro lado, o código também exclui a responsabilidade quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, II). São hipóteses de exclusão da responsabilidade por ausência de nexo causal. Explicando: se há dano verificável, mas este ocorreu não em razão de conduta do fornecedor, mas sim por comportamento negligente ou imprudente exclusivamente imputável ao consumidor ou a terceiro estranho à relação jurídica, não há liame causal entre o dano e o fornecedor. Inexiste, portanto, responsabilidade imputável a ele.

Nesses termos, esclarece Tartuce:

A culpa ou fato exclusivo de terceiro é fator obstativo do nexo de causalidade, constituindo uma das excludentes da responsabilidade civil consumerista. Não se pode esquecer que o nexo de causalidade constitui a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano causado. Assim sendo, as excludentes de nexo servem para qualquer modalidade de responsabilidade, seja ela subjetiva ou objetiva. (TARTUCE, 2016, p. 170).

A culpa exclusiva do próprio consumidor representa a culpa exclusiva da vítima, outro fator obstativo do nexo causal, a excluir a responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva. Tem-se, na espécie,

a autoexposição da própria vítima ao risco ou ao dano, por ter ela, por conta própria, assumido as consequências de sua conduta, de forma consciente ou inconsciente.

(TARTUCE, 2016, p. 172).

São essas as excludentes de responsabilidade expressamente previstas no CDC. Cabe, contudo, analisar a possibilidade da existência de outras excludentes de responsabilidade contumazes na temática, que são o caso fortuito e a força maior, ainda que não previstos no diploma legal.

3.1.1 Do caso fortuito e da força maior

O caso fortuito e a força maior são hipóteses excepcionais de exclusão do nexo causal. Sua previsão, na teoria geral do direito das obrigações, encontra-se no art. 393 do Código Civil (CC):

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (BRASIL, 2002).

Apesar de semelhantes quanto aos seus efeitos, caso fortuito e força maior não se confundem. O primeiro se trata da ocorrência de um fato imprevisível e, por esse motivo, inevitável. O segundo consiste em fato que, embora dotado de certa previsibilidade, é tão extremo que se torna inevitável.

Nesse sentido, explica Tartuce: “antes de se aprofundar o tema,

insta anotar que se segue o entendimento de Orlando Gomes, segundo qual o caso fortuito é o evento totalmente imprevisível, enquanto a força maior é o evento previsível, mas inevitável” (TARTUCE, 2016, p. 174).

Destaca-se que o fato de o CDC não os prever expressamente não obsta sua aplicação às relações de consumo. Isso ocorre porque, como dito no tópico anterior, toda e qualquer circunstância fática que elimine algum dos elementos da responsabilidade objetiva (conduta, dano e nexo causal), implicará seu afastamento, independentemente de sua previsão expressa ou não.

Sobre o tema, cumpre ressaltar a análise de Denari:

As hipóteses de caso fortuito e força maior, descritas no art. 393 do Código Civil como eximentes da responsabilidade na ordem civil, não estão elencadas entre as causas excludentes da responsabilidade civil pelo fato do produto. Mas a doutrina mais atualizada já advertiu que esses acontecimentos – ditados por forças físicas da natureza ou que, de qualquer forma, escapam ao controle do homem – tanto podem ocorrer antes como depois da introdução do produto no mercado de consumo.

Na primeira hipótese, instalando-se na fase de concepção ou durante o processo produtivo, o fornecedor não pode invocá-la para se subtrair à responsabilidade por danos.

[...]

Por outro lado, quando o caso fortuito ou força maior se manifesta após a introdução do produto no mercado de consumo, ocorre a ruptura do nexo de causalidade que liga o defeito ao evento danoso.

Nem tem cabimento qualquer alusão ao defeito do produto, uma vez que aqueles acontecimentos, na maior da parte imprevisíveis, criam obstáculos de tal monta que a boa vontade do fornecedor não pode suprir. Na verdade, diante do impacto do acontecimento, a vítima sequer pode alegar que o produto se ressentia de defeito, vale dizer, fica afastada a responsabilidade dos fornecedores pela inocorrência dos respectivos pressupostos. (DENARI, 2004, p. 196-197.).

Apesar do exposto, a doutrina majoritária restringe a maneira pela qual esses institutos devem se aplicar às relações de consumo, diferenciando fortuito interno de fortuito externo.

Nas palavras de Tartuce: “o primeiro – fortuito interno – é aquele que tem relação com o negócio desenvolvido, não excluindo a responsabilização civil. O segundo – fortuito externo – é totalmente estranho ou alheio ao negócio, excluindo o dever de indenizar” (TARTUCE, 2016, p. 174).

Em síntese, apenas pode ser considerado imprevisível ou inevitável o acontecimento cujo risco não é inerente ao negócio desenvolvido pelo fornecedor, que passa a ser denominado de “fortuito externo”. Se, por outro lado, o acontecimento decorre da essência da relação de consumo, não poderá ser considerado imprevisível nem inevitável, caracterizando “fortuito interno”.

Destaca-se que, embora se utilize a palavra “fortuito” (externo e interno), abarca-se, dentro desse conceito, tanto a força maior como o caso fortuito. Existe, portanto, caso fortuito interno e externo e força maior interna e externa, sendo ambos, usualmente, denominados apenas como “fortuito interno ou externo”.

Sobre isso, esclarece Tartuce:

Anote-se que é preciso adaptar as construções à diferenciação seguida por este autor, ou seja, também devem ser consideradas a força maior interna e a força maior externa. Isso porque estamos filiados à construção de que o caso fortuito é o evento totalmente imprevisível, e a força maior, o evento previsível, mas inevitável, conforme outrora demonstrado. Assim, ambas as categorias podem ser internas ou externas [...]. (TARTUCE, 2016, p. 175).

Esse posicionamento doutrinário foi amplamente e reiteradamente adotado pelas cortes judiciais, chegando, inclusive, a ser consolidado no Enunciado n. 443 da V Jornada de Direito Civil: “o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida” (AGUIAR JÚNIOR, 2012).

Isso posto, cabe agora esmiuçar as espécies de prestação de serviço de estacionamento, identificando o que caracteriza fortuito interno ou externo nesse tipo de relação de consumo. Para tanto, será analisada a jurisprudência nacional sobre o tema, precipuamente a do STJ, no qual se concentra a vasta maioria dos julgados.

4. Da jurisprudência do STJ

Apesar da conceituação doutrinária, permanece difícil, na prática, a distinção dos acontecimentos entre fortuito interno e externo. Por essa razão, diversos incidentes foram levados às cortes judiciais para que fosse esclarecida essa diferenciação. Em razão dessa alta demanda, foi elaborada a súmula nº 130 do STJ: “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” (BRASIL, 1995).

Isso significa que, segundo o STJ, danos ou furtos de veículos, desde que ocorridos dentro do estacionamento, são um fortuito interno, de modo que o prestador do serviço é objetivamente responsável pelo dano causado.

Sob um primeiro prisma, esse entendimento demonstra-se coerente com a exposição doutrinária já realizada, uma vez que a segurança do veículo é elemento inerente ao próprio serviço. Em outros termos: o consumidor que confia em um fornecedor e opta por deixar seu veículo sob os seus cuidados espera que a segurança de seu automóvel esteja sendo garantida. Não há como se tratar furtos ou danos a veículos como “acontecimentos imprevisíveis ou inevitáveis”, uma vez que a sua possibilidade concreta e contumaz é, em si, a razão de ser da existência do serviço em primeiro lugar.

Ressalta-se que o enunciado não pode ser interpretado com rigor literal, de forma a tentar aplicá-lo apenas quando o dano ou o furto ocorrem no veículo do cliente, de modo a se excluir os danos e furtos relativos a outros bens de sua propriedade. Efetivamente, conforme será demonstrado nos julgados, a súmula se aplica a todo e qualquer dano que ocorre com o consumidor em razão da prestação defeituosa do serviço, não se restringindo apenas aos danos no seu veículo. Não há possibilidade de outra interpretação, inclusive, uma vez que, juridicamente, não existe dano ao veículo, mas somente dano à pessoa (dano patrimonial), sendo o automóvel um bem desprovido de personalidade jurídica. A súmula, portanto, é aplicável a todo e qualquer dano patrimonial ou furto ocorrido com o usuário do serviço dentro do estacionamento, ainda que outros bens que não seu automóvel sejam os atingidos.

Há, contudo, diversos casos em que a súmula, em si, deixa de ser suficiente para a resolução do problema.

4.1. Dos roubos em estacionamentos

Embora seja expressa quanto a furtos e danos, o enunciado sumular nada diz sobre roubos. Resumidamente, enquanto o furto é a subtração não agressiva de um bem, o roubo é a sua subtração mediante violência ou grave ameaça. É evidente que, embora possuam elementos em comum, são condutas consideravelmente diferentes, tanto em nível de gravidade, como em estrutura necessária para sua prevenção.

A jurisprudência do STJ possui julgados diversos no que tange ao reconhecimento da responsabilidade por roubo. Nesse sentido, em relação a estacionamentos de Shopping Centers, já se reconheceu que persiste a responsabilidade:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO EM CANCELA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

2. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra a possibilidade de se emprestar à referida Súmula uma interpretação restritiva, fechando-se os olhos à situação dos autos, em que configurada efetivamente a falha do serviço - quer

pela ausência de provas quanto à segurança do estacionamento, quer pela ocorrência do evento na cancela do estacionamento, que se situa ainda dentro das instalações do shopping.

3. É que, no caso em julgamento, o Tribunal a quo asseverou a completa falta de provas tendentes a demonstrar a permanência na cena do segurança do shopping; a inviabilidade de se levar em conta prova formada unilateralmente pela ré - que, somente após intimada, apresentou os vídeos do evento, os quais ainda foram inúteis em virtude de defeito; bem como enfatizou ser o local em que se encontra a cancela para saída do estacionamento uma área de alto risco de roubos e furtos, cuja segurança sempre se mostrou insuficiente.

4. Outrossim, o leitor ótico situado na saída do estacionamento encontra-se ainda dentro da área do shopping center, sendo certo que tais cancelas - com controles eletrônicos que comprovam a entrada do veículo, o seu tempo de permanência e o pagamento do preço - são ali instaladas no exclusivo interesse da administradora do estacionamento com o escopo precípua de evitar o inadimplemento pelo usuário do serviço.

5. É relevante notar que esse controle eletrônico exige que o consumidor pare o carro, insira o tíquete no leitor ótico e aguarde a subida da cancela, para que, só então, saia efetivamente da área de proteção, o que, por óbvio, o torna mais vulnerável à atuação de criminosos, exatamente o que ocorreu no caso em julgamento.

6. Recurso especial a que se nega provimento. (BRASIL, 2014a, grifo nosso).

Todavia, no que tange a estacionamentos externos e gratuitos ofertados por lanchonetes, entendeu que não há possibilidade de responsabilização pelos roubos ocorridos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE MOTOCICLETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÁREA EXTERNA DE LANCHONETE. ESTACIONAMENTO GRATUITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. Ação indenizatória promovida por cliente, vítima do roubo de sua motocicleta no estacionamento externo e gratuito oferecido por lanchonete.

2. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado.

3. A teor do que dispõe a Súmula nº 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento.

4. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula nº 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em

que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).

5. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de lanchonete fast-food, ocorrido no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido, **constitui verdadeira hipótese de caso fortuito** (ou motivo de força maior) que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar (art. 393 do Código Civil).

6. Recurso especial provido. (BRASIL, 2017c, grifo nosso).

Posteriormente, em Embargos de Divergência apresentados para elucidar a aparente contradição, o STJ manteve os mesmos entendimentos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula nº 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa

de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores.

2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial **não pode ser responsabilizado por roubo** à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.

3. Embargos de divergência não providos. (BRASIL, 2019, grifo nosso).

Analisando-se os julgados, nota-se que, além de não serem contraditórios, efetivamente vão ao encontro da distinção doutrinária entre fortuito interno e externo. Isso ocorre porque há de se diferenciar os tipos de atividades desenvolvidas pelo fornecedor.

Nesse sentido, não há como equiparar um serviço lúdico de estacionamento externo e gratuito, aberto ao público, fornecido por simples comodidade, com aquele serviço elaborado e altamente estruturado a ser prestado por um estabelecimento de grande capital.

Os Shoppings, via de regra, possuem prévio conhecimento de que seus consumidores irão sair de suas dependências em posse de valores elevados de mercadoria, o que torna indispensável à prestação completa do seu serviço a elaboração de uma elaborada forma de prevenção contra crimes que tenham como fim esses bens. Entretanto, o mesmo não ocorre com as lanchonetes, que fornecem um serviço que não envolve a retirada de mercadorias de alto capital, nem a circulação de clientes em posse de vultosas quantias monetárias.

Ressalta-se que, diferentemente do que ocorre quanto à caracterização da relação de consumo, a gratuidade ou não do serviço é sim elemento importante para se delimitar a caracterização do roubo como um fortuito interno ou externo. Isso decorre do fato de

um estacionamento pago, seja um pagamento direto ou indireto, transmitir ao consumidor uma noção de que há maior estrutura e segurança naquele local, razão pela qual há o preço pelo seu uso.

Conforme será demonstrado adiante, quanto maior é a “expectativa de confiança” depositada em uma relação de consumo, maior é o “risco da atividade” pelo qual se responsabiliza o fornecedor. Em outras palavras: enquanto o fortuito interno decorre de uma quebra de confiança em relação ao serviço esperado pelo consumidor, o fortuito externo advém de um acontecimento que, de forma geral, não se esperava que o fornecedor tivesse o dever de prevenir.

Por outro lado, no instante em que ocorre o pagamento (diretamente ou indiretamente), o fornecedor acaba por aumentar a natureza do seu serviço, elevando, simultaneamente, o risco inerente a sua prestação.

Nesse sentido, o STJ decidiu que estacionamentos pagos respondem, via de regra, pelos roubos nele ocorridos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO. EMPRESA EXPLORADORA DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. É assente na jurisprudência de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção que a prática do crime de roubo no interior de estacionamento de veículos, pelo qual **seja direta ou indiretamente responsável a empresa exploradora de tal serviço**, não caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior capaz de desonerá-la da responsabilidade pelos danos suportados por seu cliente vitimado. Precedentes.

2. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula nº 168/STJ).

3. Agravo interno não provido. (BRASIL, 2017a, grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO À MÃO ARMADA OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento privado, cuja atividade-fim é a guarda e manutenção da integridade do veículo, não configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (BRASIL, 2017b, grifo nosso).

Entendimento semelhante foi obtido em relação à prática de um roubo em um veículo estacionado em *drive-thru* de uma lanchonete:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM DRIVE-THRU DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO INTERNO.

FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. O *drive-thru*, em linhas gerais, é a forma de atendimento ou de serviço diferenciado de fornecimento de mercadorias em que o estabelecimento comercial disponibiliza aos seus clientes a opção de aquisição de produtos sem que tenham que sair do automóvel. O consumidor

é atendido e servido ao “passar” com o veículo pelo restaurante, mais precisamente em área contígua à loja.

2. Assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, a rede de restaurantes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, **assumiu o dever implícito de lealdade** e segurança em qualquer relação contratual, como incidência concreta do princípio da confiança (inteligência da Súm. 130 do STJ). 3. Ao estender a sua atividade para a modalidade drive-thru, a lanchonete buscou, no espectro da atividade econômica, aumentar os seus ganhos e proventos, pois, por meio do novo serviço, ampliou o acesso aos seus produtos e serviços, facilitou a compra e venda, aumentou as suas receitas, perfazendo um diferencial competitivo para atrair e fidelizar ainda mais a sua clientela. Por conseguinte, chamou para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada em razão dessa nova atividade.

4. De fato, dentro do seu poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru ao empreendimento, acabou por incrementar, de alguma forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar os consumidores a efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, deixando-os, por outro lado, mais expostos e vulneráveis a intercorrências como a dos autos.

5. Aliás, o sistema drive thru não é apenas uma comodidade adicional ou um fator a mais de

atração de clientela. É, sim, um **elemento essencial** de viabilidade da atividade empresarial exercida, sendo o *modus operandi* do serviço, no qual o cliente, em seu veículo, aguarda por atendimento da empresa.

6. Ademais, configurada a responsabilização da fornecedora em razão da própria publicidade veiculada, em que se constata a promessa de segurança de seus clientes.

7. Na hipótese, diante de tais circunstâncias trazidas aos autos, verifica-se que o serviço disponibilizado foi inadequado e ineficiente, não havendo falar em caso fortuito ou força maior, mas sim em fortuito interno, porquanto incidente na proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida e na frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor-médio, concretizando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o cliente. O fornecedor, por sua vez, pelo que consta dos autos, não demonstrou ter adotado todas as medidas, dentro de seu alcance, para inibir, dificultar ou impedir o ocorrido na área reservada ao circuito *drive-thru* tampouco comprovou que o evento tenha se dado em outra área sobre a qual não tenha ingerência.

8. Recurso especial não provido. (BRASIL, 2018b, grifo nosso).

Da mesma forma que em relação ao estacionamento pago, o tratamento diferenciado entre a responsabilidade de um roubo ocorrido em *drive-thru* e a daquele que aconteceu em um estacionamento externo e gratuito reside no fato de que, ao prestar o primeiro, o fornecedor de serviços (lanchonete) está efetivamente

ampliando a natureza do seu serviço original e elevando o nível de segurança depositado nele pelo consumidor, o que culminou no aumento do “risco da sua atividade”.

Além disso, o prestador de *drive-thru* espera que seus clientes fiquem quantias consideradas de tempo parados, com mobilidade reduzida, em uma fila, expostos à rua. É evidente que a soma dessas variáveis eleva a vulnerabilidade dos consumidores e os torna mais suscetíveis a serem vítimas de crimes. Isso faz com que a segurança do cliente enquanto espera no *drive-thru* se torne elemento inerente ao negócio prestado, caracterizando fortuito interno, portanto, a sua violação por meio de um roubo.

4.2 Do *vallet parking*

Uma segunda problemática relativa à súmula é o fato de abordar serviços de estacionamento de uma forma generalizada, sem fazer distinção entre aqueles que são prestados em locais fechados e cobertos, daqueles que consistem na simples vigilância de veículos em ruas públicas, também conhecidos como *vallet parking*.

Exemplo contumaz desse serviço são os manobristas empregados por restaurantes para estacionar carros de clientes enquanto comem. Embora não exista um imóvel físico e fechado dentro do qual o fornecedor de serviços (restaurante) se comprometa a guardar o veículo, há um dever de conservação e guarda do veículo, equiparando-se, portanto, a um serviço de estacionamento.

Sobre o tema, já decidiu o STJ que roubos ocorridos em veículos vigiados por *vallet parking* devem ser considerados fortuitos externos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO

CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA).

1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet).

[...]

3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

[...]

5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal.

6. No serviço de manobristas de rua (valets), as **hipóteses de roubo** constituem, em princípio, **fato exclusivo de terceiro**, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso.

7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (BRASIL, 2013, grifo nosso).

Relevante é parte do voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator, no qual o magistrado pontua que, se fosse o caso de furto, o entendimento seria o oposto:

Nas hipóteses de **roubo**, **caracteriza-se o fato de terceiro** ou **força maior**, podendo-se discutir apenas eventual concorrência do demandado, mediante uma prestação defeituosa do seu serviço, para o evento danoso (fato exclusivo ou concorrente).

Nas hipóteses de **furto**, em que não há violência, **permanece a responsabilidade**, pois o serviço prestado mostra-se defeituoso por não apresentar a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. (BRASIL, 2013, grifo nosso).

Portanto, segundo o julgado, em relação ao serviço de *vallet parking*, considera-se fortuito interno a ocorrência de furtos em relação aos veículos dos consumidores, e fortuito externo a ocorrência de roubos.

Nota-se que, no caso, não se discutiu a gratuidade ou onerosidade do serviço prestado: ainda que haja algum pagamento pelo serviço, seja diretamente ao manobrista ou ao restaurante, o roubo, ainda assim, seria fortuito externo em relação à atividade. Diferencia-se, portanto, dos estacionamentos privados, nos quais, como já exposto, em razão de roubo, já reconheceu o STJ, exaustivamente, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Novamente, o cerne para a compreensão do julgado e da sua não contradição com os demais é a noção de “risco de atividade” e de “quebra de confiança legítima”, que delimitam os fortuitos interno e externo de uma atividade e das quais se valeu, no caso, o magistrado. Segundo se extrai do julgado, enquanto se demonstra razoável e esperado que os manobristas do *vallet parking* sejam capazes de vigiar

e prevenir furtos, o mesmo não ocorre com roubos, ainda mais quando se perpetram com o emprego de armas de fogo, como no caso.

Efetivamente, parece razoável se admitir que, na atividade de *vallet parking*, o consumidor espere que seu veículo, por não estar sendo guardado em local especialmente protegido, mas tão somente estacionado na rua pública, cuja vigilância incube, precipuamente, ao Estado, não esteja sob proteção tão intensa como, por exemplo, a de um estacionamento fechado. Não obstante, simultaneamente, é inerente ao serviço um grau mínimo de vigilância a ser empregado pelo fornecedor, o que certamente é esperado pelo usuário.

Nota-se, assim, um grau moderado de expectativa de confiança por parte do consumidor e, igualmente, um grau moderado de responsabilidade inerente à atividade, ainda que menor do que aquele dos estacionamentos privados. Essa singularidade exige um tratamento diferenciado.

É por esses motivos que, no entendimento do STJ, embora persista a responsabilidade do prestador de *vallet parking* pela ocorrência de furtos (fortuito interno), afasta-se, via de regra, por rompimento do nexo causal em decorrência de roubos (fortuito externo).

4.3 Dos locais mantidos pela Administração Pública

Outra situação rotineira que não é abarcada pela súmula nº 130 do STJ é quando o dano não ocorre em um estacionamento mantido por um particular, mas sim em local, mantido pela Administração Pública, em que o usuário estaciona seu veículo. São exemplos disso, entre muitos outros, os pátios de contenção de veículos por departamentos de trânsito, os pontos de pedágio e os postos de pesagem de rodovias.

Embora as hipóteses não sejam de serviço de estacionamento propriamente dito, equiparam-se a ele, uma vez que tanto o prestador particular do serviço de estacionamento como o administrador público têm, em cada caso, o dever legal, como fornecedores de uma relação

de consumo, de zelarem pela segurança dos motoristas (consumidores da relação de consumo) e dos veículos estacionados.

Já foi destacado que o CDC não impõe como elemento da relação de consumo a presença de um fornecedor de serviços de regime particular, de modo que o prestador de serviço público pode ser fornecedor de serviços. Ressalta-se que essa responsabilidade e sua natureza objetiva estão previstas também no texto da Constituição Federal (CF):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[...]. (BRASIL, 1988).

Nota-se que não é relevante que o serviço público seja prestado diretamente pela administração pública ou por meio de particular mediante delegação. Isso posto, da mesma forma que ocorre com o particular, é possível escusa da responsabilidade do fornecedor de serviço público caso se comprove que o dano adveio de fortuito externo.

Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) que a Administração Pública responde objetivamente pelos furtos relativos à veículos estacionados em postos de pesagem:

RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIÇO PÚBLICO – FURTO – POSTO DE PESAGEM – VEÍCULO. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, há responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime de furto praticado em posto de pesagem, considerada a omissão no dever de vigilância e falha na prestação e organização do serviço. (BRASIL, 2018c, grifo nosso).

Todavia, o STJ decidiu que caracteriza fortuito externo a prática de sequestro ou roubo em locais administrados por concessionárias de rodovias:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. [...]

2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário).

3. “A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado” (STF. RE 591874, Repercussão Geral).

4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público.
5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente.
6. A ocorrência de **roubo e sequestro**, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para **romper com a existência de nexo causal**, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente.
7. Recurso especial provido. (BRASIL, 2018a, grifo nosso).

No caso do último julgado, o dano ocorreu quando o usuário estava estacionado num Posto de Atendimento ao Usuário, instalado pela concessionária no percurso da rodovia. Entretanto, apesar disso, afastou o STJ a responsabilidade objetiva por rompimento do nexo causal.

Nota-se que o entendimento do STJ se fundamentou na aplicação da teoria do fortuito externo. Isso é o que se extrai do voto da relatora Ministra Nancy Andrigli:

Na hipótese em julgamento, para a determinação da responsabilidade da concessionária de serviço público (manutenção da rodovia), é necessário perquirir sobre a existência de fato de terceiro que seja capaz de excluir o nexo de causalidade entre suas ações ou omissões e os danos suportados pelos recorridos.

É o que ocorre na hipótese de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, para além da forma maior.

[...]

Menciona-se, contudo, que nem sempre o fato exclusivo de terceiro tem por consequência o afastamento da responsabilidade do agente. Isso porque há situações em que, mesmo tendo a realização do dano, por causa necessária, o fato de terceiro, tal evento é colocado na esfera de risco de determinado agente, que terá por ele de responder.

[...]

Contudo, na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente. **A segurança que ele deve fornecer aos usuários da rodovia diz respeito ao bom estado de conservação e sinalização da rodovia, não com a presença efetiva de segurança privada ao longo da estrada, mesmo que em postos de pedágio ou de atendimento ao usuário.** (BRASIL, 2018a, grifo nosso).

Percebe-se, então, que o STJ decidiu que seriam fortuitos internos, imputáveis à concessionária, apenas as atividades conexas à manutenção da rodovia, tais como a conservação do asfalto e a sinalização da estrada. Roubos e sequestros de usuários não seriam inerentes a essa atividade e caracterizariam fortuitos externos, inimputáveis, portanto.

Ao contrário dos demais julgados do STJ expostos até então, entende-se que este se apresenta em contradição com a teoria do fortuito interno e externo. Isso porque, considerando-se que há uma relação de consumo entre a concessionária de serviço público e a

vítima, reconhecimento de relação que, inclusive, ocorreu no caso em tela, há responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de fornecimento do serviço.

Nesse sentido, não há que se distinguir se o dano ocorreu em razão da omissão do Estado, que é o fornecedor titular do serviço, ou em razão de omissão da concessionária, que exerce, temporariamente, a atividade pública.

Por esse ponto de vista, é inegável que o Estado não possui o dever apenas de realizar a manutenção da rodovia, mas também de garantir a segurança daqueles que nela trafegam. Ademais, há a quebra de confiança e de expectativa entre consumidor (vítima) e fornecedor de serviço (Estado), pois se espera que o último seja capaz de prevenir quaisquer espécies de atos ilícitos que possam ocorrer dentro de suas unidades administrativas, inclusive aqueles de grande gravidade, tais como sequestros e roubos, uma vez que possui à sua disposição instituições complexas e altamente estruturadas, precipuamente a Polícia Rodoviária.

Assim, ainda que, talvez, não seja conexa à atividade precípua da concessionária nada além da manutenção da rodovia, em relação ao Estado, que é o fornecedor titular da relação de consumo, é inescusável a não garantia da segurança dos usuários. Por esse motivo, sendo solidária a responsabilidade dos fornecedores, sejam eles mediatos (Estado) ou imediatos (concessionária), deveria persistir, em relação à vítima, o direito de ser indenizada pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço de qualquer um deles.

A imputação específica da omissão, se atribuível ao Estado ou à concessionária, deveria ser analisada em eventual ação de regresso por parte da concessionária, sendo irrelevante em relação à vítima, que é usuária e consumidora do serviço prestado.

Por todo o exposto, o roubo ou sequestro de veículos dentro de locais administrados pela Administração Pública deveriam ser considerados fortuitos internos, imputáveis a qualquer um dos

fornecedores da cadeia de serviços. O mesmo raciocínio deveria ser aplicável, em tese, a todo ato ilícito praticado por inobservância do dever de segurança estatal, quando da prestação de qualquer serviço público.

5. Conclusão

O trabalho conclui que, via de regra, a prestação de serviços de estacionamento caracteriza relação de consumo, razão pela qual a responsabilidade do prestador é de natureza objetiva. Para tanto, é irrelevante que o prestador seja um particular, a administração pública ou um delegatário de serviço público, bem como que o serviço seja oneroso ou gratuito.

Essa responsabilidade pode ser afastada, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no CDC, ou nos casos de rompimento do nexo causal em decorrência de caso fortuito ou força maior. No que tange aos últimos, a escusa apenas se verifica quando o fortuito é classificado como fortuito interno, e não externo.

A distinção entre os tipos de fortuito depende de vários fatores, mas principalmente: da quebra de lealdade dos deveres do fornecedor em relação ao serviço prestado (quebra de expectativa ou de confiança) e da natureza da atividade prestada pelo fornecedor, de modo que apenas os atos conexos ao serviço prestado, ou inerentes a ele, caracterizariam fortuito interno.

Em razão disso, a caracterização ou não do fortuito externo deve observar a maneira pela qual o serviço é prestado, não podendo ser genericamente imputada a uma atividade. Nesse sentido, identificou-se a insuficiência da súmula nº 130 do STJ para resolver, em absoluto, as situações concretas possíveis.

Ademais, percebeu-se que o STJ, em regra, tem ido ao encontro da doutrina majoritária e se posicionado adequadamente quanto à caracterização do fortuito interno ou externo. Não obstante, interpretou-

-se como equivocado o julgado da corte que exclui a responsabilidade da concessionária de serviços públicos de manutenção de rodovia por danos ocorridos em razão de sequestros e roubos a veículos estacionados em unidades mantidas pela concessionária.

Conclui-se, portanto, que, embora haja, via de regra, a responsabilização objetiva do prestador do serviço de estacionamento em casos de danos ocorridos aos seus consumidores, seja este decorrente de acidentes, furtos ou roubos, essa regra não é absoluta.

Espera-se que o tema seja mais bem estudado e detalhado futuramente, elaborando-se uma teoria mais completa e correspondente à diversidade inerente às relações de consumo. Com isso, as cortes judiciais, especialmente o STJ, seriam capazes de estabelecer uma harmoniosa jurisprudência, eliminando-se uma possível sensação de insegurança jurídica por parte dos usuários e dos servidores do Poder Judiciário.

6. Referências

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado (Coord). Jornadas de Direito Civil I, II, III, IV E V: enunciados aprovados. Brasília: CJF, Centro de Estudos Judiciários, 2012.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 14 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.

Acesso em: 23 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Seção). Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.118.454/RS. Agravante: CPC Parking Administração de Estacionamentos LTDA. Agravado: Dulcenina Aparecida Pedrolli. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 25 de outubro de 2017. Brasília, DF: STJ, [2017a]. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=+1911601=89-2006.8.21.0001.&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Seção). Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.431.606/SP. Embargante: Renato Martinez da Silva. Embargado: Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 27 de março de 2019. Brasília, DF: STJ, [2019]. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=EResp%201431606>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.038.841/RS. Agravante: Autoser Lam LTDA - ME e Luis Antônio Podeleski. Agravado: Vitor Rubem Gallas. Relator: Min. Raul Araújo, 09 de maio de 2017. Brasília, DF: STJ, [2017b]. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=0181870-96.2012.8.21.0001&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial 1.269.691/PB. Recorrente: Manaira Administradora de Bens LTDA. Recorrido; Valéria Maria Simões da Silva. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Relator para acórdão: Min. Luis Felipe Salomão 21 de novembro de 2013. Brasília, DF: STJ, [2014a]. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1155858&num_registro=201101215179&da

ta=20140305&peticao_numero=-1&formato=HTML. Acesso em: 29 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.749.941/PR. Recorrente: Rodovia das Cataratas S/A Ecocataratas. Recorridos: Dorival José dos Reis, Sandra Rosa dos Reis e Camila dos Reis Altmann. Relatora: Min. Nancy Andrichi, 04 de dezembro de 2018. Brasília, DF: STJ, [2018a]. Disponível em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661787133/recurso-especial-resp-1749941-pr-2017-0240892-4/inteiro-teor-661787143>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial 1.450.434/SP. Recorrente: Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA. Recorrido: Artur Luiz Godoy Fernandes. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 18 de setembro de 2018. Brasília: STJ, [2018b]. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=9158288-20.2005.8.26.0000&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.431.606/SP. Recorrente: Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA. Recorrido: Renato Martinez da Silva. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Relator para acórdão: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15 de agosto de 2017. Brasília, DF: STJ, [2017c]. Disponível em:<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=EResp%201431606>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 519.310/SP. Recorrente: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Recorrido: Sociedade de Beneficência e Filantropia São Cristóvão. Relatora: Min. Nancy Andrichi, 20 de abril de 2004. Brasília, DF: STJ, [2004b]. Disponível em:https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=468454&num_

registro=200300580885&data=20040524&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.321.739/SP. Recorrente: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A. Recorrido: Butoh Restaurante LTDA. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 05 de setembro de 2013. Brasília, DF: STJ, [2013]. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24164523/recurso-especial-resp-1321739-sp-2012-0088797-0-stj/inteiro-teor-24164524?ref=juris-tabs>. Acesso em: 31 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Diário de Justiça: segunda seção, Brasília, DF, ano 85, p. 8294, 04 abr. 1995.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Recurso Extraordinário 598.356/SP. Recorrente: Transportadora Caho LTDA. Recorrido: Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A. Relator: Min. Marco Aurélio, 08 de maio de 2018. Brasília, DF: STF, [2018c]. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2668434>. Acesso em: 31 jul. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Assalto à mão armada ocorrido no interior de estacionamento pago: empresa tem responsabilidade civil. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2017a. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/08f36fcf88c0a84c19a6ed437b9cbcc9>>. Acesso em: 15 ago. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Concessionária de rodovia não responde civilmente por roubo e sequestro. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2018. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3487596cf54cb393afddaa965714ab1f>. Acesso em: 19 ago. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Lanchonete não tem o dever de indenizar consumidor vítima de roubo ocorrido no estacionamento

externo e gratuito do estabelecimento. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2017b. Disponível em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b62d343d76d2ab4e2d65e547b0f4c75c>. Acesso em: 25 jul. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O roubo à mão armada em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso configura furto externo, afastando a responsabilização do estabelecimento comercial. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2019. Disponível em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a14185bf0c82b3369f86efb3cac5ad28>. Acesso em: 25 jul. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Roubo ocorrido em veículo sob a guarda de vallet parking que fica localizado em via pública. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2013. Disponível em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1905aedab9bf2477edc068a355bba31a>. Acesso em: 15 ago. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Tentativa de roubo ocorrida no estacionamento de shopping center. Buscador Dizer o Direito, Manaus, 2014. Disponível em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9>. Acesso em: 25 jul. 2020.

DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. V. 7. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

TARTUCE, Flávio; NEVES; Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Forense, 2016.

CAPÍTULO 2

Inaplicabilidade do CDC ao contrato de conta-corrente entre corretora de *bitcoin* e instituição financeira

*Izabela Sedlmaier Souza*²

Resumo:

O presente artigo analisará julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que foi decidido que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de conta-corrente mantido entre corretora de *bitcoin* e instituição financeira. No caso concreto, o banco notificou a corretora que não tinha mais interesse no contrato e que encerraria a conta-corrente, usada para comercialização das *bitcoins*. Inconformada, a corretora judicializou a questão, alegando que se trata de prática abusiva vedada pelo CDC. Ao analisar o caso por meio de Recurso Especial, o STJ decidiu que a corretora não é destinatária final do serviço de conta-corrente, já que o utiliza como incremento de sua atividade profissional, por isso não há que se aplicar o CDC. Após apresentação do caso concreto e do conceito de consumidor adotado pelas fontes do Direito, foi concluído que o STJ agiu com acerto. Isso porque, além de não haver prática abusiva por parte do banco, a corretora não pode ser considerada como consumidora com base na teoria finalista, adotada pelo CDC, STJ e doutrina como regra geral, e nem há vulnerabilidade de sua parte que autorize a aplicação da teoria finalista mitigada, adotada, de forma excepcional, por aquelas fontes do Direito.

2 Pós-graduanda em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direitos Humanos pela Faculdade UniAmérica, pós-graduada em Ciências Criminais pela Faculdade Damásio, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), advogada.

Palavras-chave: Conceito de consumidor. Teoria finalista mitigada. Corretora de *bitcoin*. Encerramento de conta-corrente. Prática abusiva.

1. Introdução

O presente artigo analisará julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi decidido que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de conta-corrente entre corretora de *bitcoin* e instituição financeira.

No caso concreto, a corretora Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda mantinha conta-corrente junto ao banco Itaú, para receber o pagamento pelas *bitcoins* comercializadas. O banco notificou a corretora de que não tinha mais interesse no contrato e que, portanto, encerraria a conta-corrente.

Diante disso, a corretora judicializou a questão, alegando que a postura do banco constitui prática abusiva vedada pelo CDC. Analisando o Recurso Especial interposto, o STJ decidiu que o CDC não é aplicável ao caso, uma vez que a corretora não se enquadra como consumidora na situação analisada.

Neste trabalho, será apresentado o caso concreto com mais detalhes, inclusive técnicos, no primeiro capítulo. Em seguida, será abordado o conceito de consumidor, com apresentação das teorias existentes e apontamento de qual foi adotada pelo CDC, pela doutrina e pelo STJ.

Por fim, à luz dessas teorias, será analisado se a corretora poderia ser enquadrada como consumidora no caso concreto e, por consequência, o (des)acerto da decisão do STJ.

2. Caso concreto: disputa entre corretora de *bitcoin* e instituição financeira

Bitcoin é um dinheiro igual ao Real, Dólar e Euro. A diferença é que ele é inteiramente digital, existe apenas na internet. A moeda digital permite o envio e recebimento de valores sem limitação territorial e de forma anônima. Além disso, não há necessidade de intermediário, como banco, para sua circulação e nem há um órgão responsável pela regulamentação (COINTIMES, 2018).

Nesse sentido, é a lição da doutrina:

O bitcoin é uma criptomoeda que utiliza uma tecnologia ponto a ponto (peer-to-peer) para criar um sistema de pagamentos on-line que não depende de intermediários e não se submete a nenhuma autoridade regulatória centralizadora. O código do bitcoin é aberto, seu design é público, não há proprietários ou controladores centrais e qualquer pessoa pode participar do seu sistema de gerenciamento coletivo. Enfim, o bitcoin é uma inovação revolucionária porque é o primeiro sistema de pagamentos totalmente descentralizado. (RAMOS, 2018 apud BRASIL, 2018).

Apesar de a moeda poder ser adquirida sem intermediário, há corretoras de *bitcoins*, nas quais se pode comprá-la. Para efetuar a compra, o cliente repassa dinheiro para a corretora, por meio de depósito bancário em sua conta-corrente.

No caso concreto, a corretora de *bitcoin* mantinha conta-corrente no banco Itaú para tal finalidade. Ocorre que o banco notificou a corretora que não tinha mais interesse em manter a conta e que a

encerraria.

Inconformada, a corretora judicializou a questão, pedindo a manutenção da conta-corrente. Alegou que a recusa do banco em fornecer o serviço constitui prática abusiva, vedada pelo CDC, no incisos II e IX do artigo 39.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; [...]. (BRASIL, 1990).

O caso chegou até o STJ, por meio da interposição de Recurso Especial. O Tribunal entendeu que não há relação de consumo, porque a corretora não se enquadra como consumidora.

Para o Tribunal, a corretora utilizava a conta-corrente para incremento de sua atividade comercial, não sendo a destinatária final do serviço, o que inviabiliza o reconhecimento da relação de consumo, nos termos da sua jurisprudência.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR EMPRESA QUE EFETUA INTERMEDIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO, BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A MANTER CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO

POR REGULAR NOTIFICAÇÃO. LICITUDE.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...].

2. O serviço bancário de conta-corrente afigura-se importante no desenvolvimento da atividade empresarial de intermediação de compra e venda de bitcoins, desempenhada pela recorrente, conforme ela própria consigna, mas sem repercussão alguma na circulação e na utilização dessas moedas virtuais, as quais não dependem de intermediários, sendo possível a operação comercial e/ou financeira direta entre o transmissor e o receptor da moeda digital. Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que a utilização de serviços bancários, especificamente o de abertura de conta-corrente, pela insurgente, dá-se com o claro propósito de incrementar sua atividade produtiva de intermediação, não se caracterizando, pois, como relação jurídica de consumo – mas sim de insumo –, a obstar a aplicação, na hipótese, das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

[...]. (BRASIL, 2018).

Para avaliar se a corretora se enquadra ou não como consumidora no caso concreto e o conseqüente (des)acerto da decisão do STJ, necessário verificar o conceito de consumidor, adotado pelas fontes do Direito, o que se faz a seguir.

3. Conceito de consumidor

Para o CDC, há dois tipos de consumidor: o *stricto sensu/standart* e o equiparado. O primeiro tipo, que é o mais comum, será conceituado logo abaixo e, em seguida, será tratado do consumidor equiparado.

3.1. Consumidor *standart/stricto sensu*

A definição de consumidor *standart/stricto sensu* é trazida pelo próprio CDC, em seu artigo 2º, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final (BRASIL, 1990).

Com a finalidade de definir o que seja destinatário final no referido conceito, surgiram duas teorias: a maximalista, também conhecida como objetiva, e a finalista, denominada também de subjetiva.

Para teoria maximalista, destinatário final é o destinatário fático do bem ou serviço, pouco importante a destinação econômica. Assim, se uma costureira adquire tecido para fabricação de roupas, ela é considerada consumidora, sendo indiferente se o tecido será utilizado na atividade profissional ou para uso próprio.

Por outro lado, para corrente finalista, é destinatário final aquele que retira o bem do mercado, colocando fim na cadeia de produção. De acordo com essa teoria, a costureira citada não se enquadra como consumidora, já que o tecido adquirido continuará circulando no mercado, por meio das roupas fabricadas.

A teoria finalista não considera como consumidor o empresário que adquire produto ou serviço que vá ser utilizado na atividade comercial desenvolvida, já que, nesse caso, ele não será o destinatário final desse bem ou serviço.

De acordo com Tartuce e Neves (2017), o CDC adotou a teoria finalista, já que exige que o consumidor seja o destinatário final do bem ou serviço. Alerta o doutrinador que a destinação final deve ser fática (consumidor deve ser o último na cadeia de transmissão do bem) e econômica (produto ou o serviço não pode ser utilizado para o lucro, repasse ou transmissão onerosa). Nesse sentido,

Na essência, a teoria finalista ou subjetiva foi a adotada expressamente pelo art. 2º do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor para a qualificação do consumidor, pela presença do elemento da destinação final do produto ou do serviço. Tem prevalecido no Brasil a ideia de que o consumidor deve ser destinatário final fático e econômico, conforme as preciosas lições de Claudia Lima Marques:

“Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo essa interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção, cujo preço será incluído no preço final do profissional para adquiri-lo. Nesse caso, não haveria exigida ‘destinação final’ do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Essa interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável.” (MARQUES, 2004 apud TARTUCE; NEVES, 2017, p. 96).

Partindo do pressuposto de que a teoria adotada pelo CDC para caracterização de consumidor é a finalista, não resta dúvida de que

aqueles que possuem pequenos negócios não seriam consumidores quando adquiressem bem ou serviço para o exercício de sua atividade empresarial.

Voltando ao exemplo da costureira, eventual ação judicial contra o fornecedor do tecido adquirido seria muito mais custosa apenas por não haver relação de consumo. Como exemplo, o ônus da prova caberia à costureira como regra geral, a revisão contratual teria requisitos mais rígidos e a ação não tramitaria, via de regra, no domicílio dela.

Considerando situações como essa, surgiu a teoria finalista mitigada, também conhecida como finalista aprofundada, que aceita a caracterização da relação de consumo quando o consumidor utiliza o bem ou serviço em sua atividade empresarial, mas desde que esse consumidor seja vulnerável na relação de consumo.

Nesse sentido, é a lição da doutrina: “abrandar-se, porém, em determinados casos, a teoria finalista (ou subjetiva), para aplicar o CDC a consumidores profissionais, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.” (BRAGA NETTO, 2013, p. 114).

O STJ adota, como regra geral, a teoria finalista. Excepcionalmente, admite a teoria finalista mitigada para reconhecimento da relação de consumo quando há vulnerabilidade do consumidor, ainda que ele não seja o destinatário final e que o bem ou serviço adquirido sejam utilizados em sua atividade empresarial. Para o Tribunal, a vulnerabilidade vai além da seara econômica, podendo existir também do ponto de vista jurídico, técnico e informacional.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA

MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

[...].

4. Agravo interno não provido. (BRASIL, 2020).

No mesmo sentido, outro acórdão do Tribunal:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritivo art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido

como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados

insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). [...]. (BRASIL, 2012).

De acordo com Garcia (2017, p. 23), entende-se por vulnerabilidade técnica a ausência de conhecimento técnico do produto comercializado. Já a vulnerabilidade jurídica ou científica se caracteriza pela ausência de conhecimento relativa àquela relação, podendo ser jurídico, contábil, econômico. Por outro lado, a vulnerabilidade econômica é a vulnerabilidade real diante do parceiro contratual, em razão de seu poder econômico. Por sua vez, a vulnerabilidade informacional se caracteriza pela ausência de informação importante sobre o produto, o que pode influenciar no poder de escolha do consumidor.

Analisando caso alheio ao deste trabalho, a Ministra Nancy Andrighi tratou das maneiras pelas quais o consumidor pode se mostrar vulnerável numa relação de consumo, definindo com precisão as espécies de vulnerabilidade consideradas pela doutrina e pela jurisprudência, conforme se vê em trecho de sua manifestação transcrita abaixo.

A **vulnerabilidade técnica** implica ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo. No sistema do CDC, ela é presumida no caso do consumidor não-profissional, mas pode, excepcionalmente, alcançar o consumidor profissional, nas hipóteses em que o produto ou serviço adquirido não tiver relação com a sua formação, competência ou área de atuação.

A **vulnerabilidade jurídica ou científica** pressupõe falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo. Ela se presume para o consumidor pessoa física não-profissional. Essa presunção se

inverte no caso de profissionais e pessoas jurídicas, partindo-se da suposição de que realizam seus atos de consumo cientes da respectiva repercussão jurídica, contábil e econômica, seja por sua própria formação (no caso dos profissionais), seja pelo fato de, na consecução de suas atividades, contarem com a assistência de advogados, contadores e/ou economistas (no caso das pessoas jurídicas).

A **vulnerabilidade fática ou socioeconômica** abrange situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor.

Além das três espécies acima, nosso atual estágio de evolução social e tecnológica trouxe relevo também para a **vulnerabilidade informacional**. O que antes podia ser considerado uma espécie de vulnerabilidade técnica, ganhou importância e individualidade com a denominada era da informação ou era digital, período que sucede a era industrial e que se caracteriza pela troca de informações de maneira globalizada e em tempo real. Isso, de um lado, implicou amplo acesso à informação, mas, por outro, conferiu enorme poder àqueles que detêm informações privilegiadas. Essa realidade, aplicada às relações de consumo – em que a informação sobre o produto ou serviço é essencial ao processo decisório de compra – evidencia a necessidade de se resguardar a vulnerabilidade informacional do consumidor. (BRASIL, 2012, grifo nosso).

A título de exemplo, no acórdão abaixo, o STJ analisou caso em

que havia relação de consumo entre caminhoneiro e concessionária de caminhão, diante da vulnerabilidade desse consumidor frente à concessionária.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAMINHONEIRO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É relação de consumo a estabelecida entre o caminhoneiro que reclama de defeito de fabricação do caminhão adquirido e a empresa vendedora do veículo, quando reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré. Precedentes.
2. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade de acesso à Justiça, é nula a cláusula de eleição de foro. Precedentes.
3. A condição de vulnerabilidade do recorrido firmada a partir dos elementos de convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL, 2014).

Por outro lado, neste outro julgado também analisado pelo STJ, não se reconheceu relação de consumo entre caminhoneiro e concessionária de caminhão, ao argumento de que o caminhoneiro não era vulnerável, já que possuía uma frota muito grande de veículo e atuava no mercado há um tempo, tendo, portanto, conhecimento do seu funcionamento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. DEFEITO NOS MOTORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.

TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

3. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, conclui que a hipótese não comporta exceção, argumentando que “o fato de já atuar no mercado por longo período de tempo, bem como levando-se em consideração a expressividade de sua frota de veículos, não há como prevalecer a presunção de vulnerabilidade da

empresa, que possuiu experiência mercadológica suficiente ao exercício de seus direitos, não se revelando hipossuficiente ao ponto de vista de seus parceiros comerciais”. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para o exame do dissídio jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (BRASIL, 2019).

Com esses dois casos, semelhantes mas com desfecho distintos, percebe-se que a análise da vulnerabilidade para aplicação da teoria finalista mitigada é casuística, de acordo com cada caso concreto.

Pelo exposto, no que tange ao conceito de consumidor *standart*, vê-se que a regra geral é a adoção da teoria finalista, tanto pelo Código, quanto pela doutrina e jurisprudência. Excepcionalmente, havendo vulnerabilidade por parte do consumidor, adota-se a teoria finalista mitigada.

3.2 Consumidor equiparado

Além do consumidor *standart*, o CDC considera também como consumidor, por equiparação: a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (parágrafo único do artigo 2º); todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso (artigo 17); bem como todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas (artigo 29).

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

(BRASIL, 1990).

Apresentado o conceito de consumidor adotado pelas fontes do Direito, passa-se a analisar se, no caso objeto deste trabalho, a corretora de *bitcoin* se enquadra ou não como consumidora e o consequente (des)acerto da decisão do STJ que não a considerou como tal.

4. Descaracterização da corretora de *bitcoin* como consumidora e acerto da decisão do STJ

Para verificar se o CDC se aplica ao caso, necessário analisar se a corretora pode ser considerada como consumidora no caso concreto. Tal como mencionado, há duas categorias de consumidor: o *standart* e o equiparado.

Em relação ao primeiro conceito, o de consumidor *standart*, necessário que se adquira bem ou serviço como destinatário final para ser considerado consumidor, de modo que a aquisição para atividade empresarial desenvolvida descaracteriza a relação de consumo, conforme a teoria finalista.

No caso concreto, o serviço de conta-corrente era utilizado para o exercício da atividade empresarial da corretora. Ela não era

destinatária fática nem econômica desse serviço, de tal forma que não pode ser enquadrada como consumidora.

Nesse sentido, trecho do voto do ministro Marco Aurélio Bellizze:

Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que a utilização de serviços bancários, especificamente o de abertura de conta-corrente, pela insurgente, dá-se com o claro propósito de incrementar sua atividade produtiva de intermediação, não se caracterizando, pois, como relação jurídica de consumo — mas sim de insumo —, a obstar a aplicação, na hipótese, das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. (BRASIL, 2018).

Analizando o caso sob a ótica da teoria finalista mitigada, necessário avaliar se havia vulnerabilidade por parte da corretora. Trata-se de uma grande sociedade empresária, consolidada no mercado, com estrutura e conhecimento acerca do serviço prestado, não havendo vulnerabilidade em nenhum de seus aspectos (técnico, fático, informacional ou jurídico).

Verificado que a corretora não se encaixa no conceito *standart* de consumidor, nem pela aplicação da teoria finalista nem pela finalista mitigada, necessário avaliar a questão do ponto de vista do consumidor por equiparação.

O CDC considera como consumidor, por equiparação: a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (parágrafo único do artigo 2º); todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso (artigo 17); bem como todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas (artigo 29).

Verifica-se que não se trata da coletividade de pessoas intervindo

nas relações de consumo muito menos de produto ou serviço defeituoso. Em relação à exposição à prática abusiva, merece uma melhor apuração.

A corretora alegou que a conduta do banco de encerrar a conta-corrente consiste em prática abusiva por deixar de oferecer serviço a quem tenha condição e interesse em adquiri-lo, violando, assim, o artigo 6º, IV e o artigo 39, II e IX do CDC.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; (BRASIL, 1990).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (BRASIL, 1990).

No caso concreto, a corretora foi notificada previamente do encerramento da conta-corrente. Como se trata de um contrato continuado, normal que a intenção das partes em mantê-lo seja reavaliada no decorrer do tempo.

Isso está em conformidade, inclusive, com a liberdade de contratar, segundo a qual as partes têm a liberdade de celebrar

negócio jurídico de acordo com os seus interesses, não podendo ser compelidas a se manter numa relação contratual que deixou de lhes apresentar vantagem.

Além disso, o desinteresse em manter conta-corrente por parte do banco encontra respaldo legal. A Resolução 2.025/1993 do Conselho Monetário Nacional (CMN) permite essa conduta às instituições financeiras, desde que haja prévio aviso.

Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato.

[...].

Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista. (BRASIL, 1993).

Nesses termos, é o voto do ministro Marco Aurélio Bellizze:

Diante de tais considerações de ordem conceitual, é relevante deixar assente que o encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. A esse propósito, destaca-se que Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho

Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). E, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de Resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. (BRASIL, 2018).

Desse modo, verifica-se que a corretora no caso concreto não se enquadra como consumidora *standart* e nem equiparada, de modo que o STJ agiu com acerto ao decidir a questão nesse sentido, não considerando a relação como consumerista.

5. Conclusão

Finalizado este trabalho, observa-se que a corretora não se enquadra como consumidora em nenhum dos conceitos adotados pelo CDC, muito menos com base na teoria finalista e na teoria finalista mitigada.

Com base na teoria finalista, a corretora não pode ser considerada como consumidora, porque não é destinatária final do serviço de conta-corrente junto ao banco, utilizando-o como incremento de sua atividade empresarial.

Também não é caso de se aplicar a teoria finalista mitigada, uma vez que a corretora não se mostra vulnerável, seja do ponto de vista técnico, fático, informacional ou mesmo jurídico.

Ainda que a corretora fosse considerada consumidora, não houve prática abusiva por parte do banco ao encerrar a conta-corrente, já que

há amparo legal para tal conduta por parte das instituições financeiras quando há prévio aviso, o que ocorreu no caso concreto.

Desse modo, conclui-se que a decisão do STJ de não considerar a corretora como consumidora e, como consequência, de não aplicar ao CDC ao caso concreto foi correta e em conformidade com o posicionamento adotado pela sua jurisprudência, pela doutrina e pelo próprio CDC.

6. Referências

BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. Salvador: JusPodivm, 2013.

BRASIL. Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil. Resolução BACEN/CMN n. 2.025, de 24 de novembro de 1993. Altera e consolida as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos. Brasília, DF: Bacen, 1993. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1993/pdf/res_2025_v5_L.pdf. Acesso em: 13 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 14 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Interno em Recurso Especial 1.545.508/RJ. Agravante: SPE23 Global Prêmio Bora Itaborai Suites Empreendimentos S.A. Agravados: CPMM e ISMM. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 11 de fevereiro de 2020. Brasília, DF: STJ, [2020]. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201902097809&dt_publicacao=18/02/2020. Acesso em: 13 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Regimental em Agravo de Recurso Especial 1.083.962/ES. Agravante: J. Alves Transportes LTDA. Agravado: Man Latin America Indústria e

Comércio de Veículos LTDA. Relator: Min. Raul Araújo, 11 de junho de 2019. Brasília, DF: STJ, [2019]. Disponível em:https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201700813320&dt_publicacao=28/06/2019. Acesso em: 13 de ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Regimental em Agravo de Recurso Especial 426.563/PR. Agravante: Sponchiado Veículos e Transportes LTDA. Agravado: Gilmar Bonifácio. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 03 de junho de 2014. Brasília, DF: STJ, [2014]. Disponível em:https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201303663968&dt_publicacao=12/06/2014. Acesso em: 13 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.195.642/RJ. Recorrente: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Embratel. Recorrido: Juleca 2003 Veículos LTDA. Relator: Min. Nancy Andrighi, 13 de novembro de 2012. Brasília, DF: STJ, [2012]. Disponível em:https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000943916&dt_publicacao=21/11/2012. Acesso em: 13 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.696.214/SP. Recorrente: Mercado Bitcoin Serviços Digitais LTDA. Recorrido: Itaú Unibanco S.A. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 09 de outubro de 2018. Brasília, DF: STJ, [2018]. Disponível em:https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201702244334&dt_publicacao=16/10/2018. Acesso em: 13 ago. 2020.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. (Coleção Leis Especiais para Concursos)

HONORATO, Isac. O que é Bitcoin? Qual a cotação e como funciona o Bitcoin? Cointimes, 2018. Disponível em: <https://cointimes.com.br/o-que-e-bitcoin-cotacao-e-como-funciona/>. Acesso em: 14 ago. 2020.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 8. ed. Rio

de Janeiro: Método, 2018.

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

CAPÍTULO 3

A cobrança de uma “taxa de conveniência” pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet

Larissa de Paula Xavier de Figueiredo³

Resumo:

O Código de Defesa do Consumidor tem a função primordial de proteção aos vulneráveis consagrando um novo microsistema de direitos e deveres inerentes às relações de consumo. No presente artigo, trataremos a respeito de um caso julgado referente à viabilidade ou não da cobrança de uma taxa de conveniência por parte da empresa especializada pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet. Trataremos dos dois entendimentos divergentes o primeiro do ano de 2018 no qual o STJ entendia pela ilicitude da mencionada taxa e a alteração de entendimento no ano de 2019, no qual o STJ julgou pela possibilidade da cobrança dessa taxa nesses casos.

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Das práticas comerciais. Das práticas abusivas. Venda casada. Taxa de conveniência.

1. Introdução

O presente artigo tem como finalidade fazer uma breve análise do julgado do Superior Tribunal de Justiça da 3ª Turma. A situação permeia sobre a possibilidade ou não de cobrança de taxa de conveniência, repassada ao consumidor pela empresa especializada na compra de ingressos pela internet para espetáculos culturais.

³ Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Escola Paulista de Direito – SP. Graduada em Direito pela Universidade de Braz Cubas – Mogi das Cruzes/SP. Advogada e mediadora de conflitos.

Preliminarmente, faremos uma breve análise estrutural do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos conceitos-chave, princípios.

Logo adiante, adentraremos no estudo do caso, e por fim ao julgado propriamente dito, conforme mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, traremos das razões do antigo entendimento, bem como das principais fundamentações que levaram a alteração da decisão pela referida Turma.

2. Das práticas comerciais

Inicialmente é importante mencionar que o Código de Defesa do Consumidor é organizado em Títulos: Título 1 – Dos direitos do consumidor, Título II – Das infrações penais, Título III – Defesa do consumidor em juízo, Título IV – Do sistema nacional de defesa do consumidor, Título V – Da Convenção coletiva de consumo, Título VI – Disposições finais.

Por sua vez, Título I é dividido em sete Capítulos: I – Disposições gerais, II – Da política nacional de relações de consumo, III – Dos direitos básicos do consumidor, IV – Da qualidade de produtos e serviços e prevenção e da reparação dos danos, V – Das práticas comerciais, VI – Da proteção contratual e por fim, VII – Das sanções administrativas.

Por sua vez, o capítulo V é subdividido em seis seções: I – Das disposições gerais, II – Da oferta, III – Da publicidade, IV – Das práticas abusivas, V – Da cobrança de dívidas, VI – Dos bancos de dados e cadastro de consumidores.

No presente artigo, trataremos especificadamente do capítulo V, analisando cada uma de suas seções, a fim de compreendermos melhor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O capítulo tem início com o artigo 29 do CDC que estabelece o

terceiro conceito de consumidor por equiparação, aduzindo que “para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas” abrangem, neste sentido, as disposições do CDC relativas às fases pré-contratual, de execução, e pós-contratual, pertinentes ao contrato de consumo. Segundo Bruno Miragem (2020):

Atualmente, a aplicação do conceito de consumidor equiparado do artigo 29 permitiria converter o CDC em paradigma de controle de todos os contratos no direito privado brasileiro. Todavia, a tendência – correta a nosso ver – tem sido de aplicação do conceito em acordo com o princípio da vulnerabilidade presente no Código, ou ainda com os riscos que determinadas práticas comerciais oferecem à coletividade. (MIRAGEM, 2020, p. 143).

Nesse sentido destaca-se que o elemento vulnerabilidade está presente a fim de proteger ainda mais os consumidores destinatários finais e também aqueles que necessitam em razão de alguma condição de inferioridade em que se encontrem nas relações firmadas com o fornecedor. Acrescenta ainda nesse sentido Fabrício Bolzan de Almeida (2020) que atinge as pessoas jurídicas também.

Sobre o tema, destaca-se que a vulnerabilidade não é atributo exclusivo do consumidor pessoa física, mas atinge também pessoas jurídicas, oportunidade em que poderão ser consideradas consumidoras por equiparação nos termos do art. 29 do CDC. Assim, nas oportunidades em que uma empresa for exposta a uma prática comercial ou contratual abusiva e desde que demonstrada sua hipossuficiência no caso concreto, será considerada

consumidora por equiparação para os defensores da tese ora apresentada. (ALMEIDA, 2020, p. 120).

Já o artigo 30 do CDC descreve que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, consagrando assim o princípio da vinculação da oferta. Portanto, a oferta publicitária, no âmbito do CDC, é irretratável. Sendo que eventual recusa de cumprimento de oferta gera o efeito previsto no art. 35 do CDC, o qual dispõe que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I - exigir o cumprimento forçado da obrigação (tutela específica), nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. (BRASIL, 1990).

As informações descritas na oferta devem ser “*corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros*”. O código ainda traz mais alguns detalhes quanto a oferta, como no caso da manutenção de reposição de peças, proibida a publicidade via telefone se onerosa ao consumidor.

Quanto a publicidade, tópico mais relevante desse capítulo,

importante trazer um conceito trazido por Cláudia Lima Marques: *“toda informação ou comunicação difundida com o fim direto ou indireto de promover, junto aos consumidores, a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço, qualquer que seja o local ou meio de comunicação utilizado”* (MARQUES, 2010, p. 805).

Ademais, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves atentam para uma relevante questão:

Do ponto de vista técnico-terminológico, não se pode confundir a publicidade, que tem fins de consumo e de circulação de riquezas, com a propaganda, que tem finalidades políticas, ideológicas ou sociais. Isso, apesar da existência de alguns doutrinadores que entendem que as expressões são sinônimas do ponto de vista jurídico. (TARTUCE; NEVES, 2018, p. 396).

Nesse sentido, urge destacar os princípios que regem a publicidade: Princípio da identificação da publicidade descrito no artigo 36 CDC, Princípio da vinculação contratual da publicidade descrito nos artigos 30 e 35 do CDC, Princípio da transparência da fundamentação da publicidade previsto no parágrafo único do artigo 36 do CDC, Princípio da proibição da publicidade ilícita, do artigo 37, Princípio da inversão do ônus da prova previsto no artigo 38 do CDC, Princípio do dever da contrapropaganda, artigo 60 CDC.

O Código de Defesa do Consumidor, preocupado com os possíveis abusos contra o consumidor elencou uma série de situações exemplificativas abusivas e as coibiu de maneira absoluta, porém não trouxe nenhum conceito expresso do que seria uma prática abusiva, todavia a doutrina identifica como uma *“desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor”* (GRINOVER; BENJAMIN; FINK; FILOMENO; NERY JÚNIOR; DENARI, 2018, p. 375).

Neste artigo focaremos apenas no inciso I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, exemplo mais conhecido como “venda casada” pela doutrina e jurisprudência, no qual o fornecedor está proibido de vincular a aquisição de um produto a outro ou a contratação de mais de um serviço ou, ainda, a aquisição de um produto desde que contrate certo serviço. Quanto a esse inciso é relevante destacar o entendimento de Fabrício Bolzan:

Em nossa opinião, a exigência pelo consumidor do cumprimento da lei no tocante à vedação da venda casada deverá levar em consideração os seguintes critérios:

- que os produtos e os serviços sejam usualmente vendidos separados;
- que a solicitação da unidade não desnature o produto — exemplo: se retirar um iogurte da cartela de seis, ninguém mais vai querer comprar os cinco remanescentes, nem poderia o fornecedor, nestes casos, vender o produto com a ausência de complemento;
- que a conduta do consumidor não prejudique o fornecedor a ponto de este não conseguir mais vender determinado produto em razão da ausência de sua completude, contexto que ocorreria certamente caso o consumidor exigisse cem gramas a serem retiradas do saco de um quilo de arroz. (ALMEIDA, 2020, p. 836).

Destaca-se que um dos julgados mais importantes proferidos pelo STJ no ano de 2019 envolveu o reconhecimento da abusividade da cobrança da “taxa de conveniência” na venda de ingressos em

meio virtual - internet vinculada a uma única intermediadora. O STJ considerou a prática abusiva como sendo uma modalidade de venda casada indireta ou “às avessas”.

No entanto, adiantamos que recentemente o STJ reformulou seu entendimento e passou a considerar lícita a cobrança da referida “taxa de conveniência” pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet. Passamos agora para a análise propriamente dos julgados.

3. Informativo 644 STJ - Da proibição de cobrança da taxa de conveniência pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet

Feita uma breve introdução teórica do Código de Defesa do Consumidor quanto às práticas comerciais, passo agora para a análise dos julgados dos anos da 3ª Turma do STJ sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 e sua recente alteração de entendimento pela mesma Turma e também de relatoria da ministra Nancy Andrighi julgado em 06/10/2020, acerca da possibilidade ou não de cobrança da taxa de conveniência pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet.

O referido caso tratava quanto ao oferecimento de ingressos ao público, que pode ocorrer pelo próprio promotor ou produtor do evento, ou por meio de pessoa ou empresa terceirizada. Algumas dessas empresas especializadas em venda de ingressos cobram do consumidor um “valor” adicional pelo fato de estarem comprando os ingressos por meio de uma página na internet, esse valor ficou conhecido como “taxa de conveniência”.

A princípio, o STJ entendeu que essa cobrança “extra” feita pelas empresas terceirizadas não seria válida sob o argumento de que essas celebram um contrato com o promotor ou produtor do evento para que possam conduzir o negócio, sendo chamado pelo Código Civil de “contrato de corretagem” descrito no artigo 722 CC:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa (empresa de ingressos), não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda (empresa que está produzindo o show) um ou mais negócios (venda de ingressos), conforme as instruções recebidas. (BRASIL, 2002).

O STJ entendia que não havia relação contratual direta entre a empresa contratada para a venda de ingressos e o consumidor. Logo, quem deveria arcar com esse valor “a mais” deveria ser a empresa produtora do espetáculo, conforme prevê o artigo 725 do CC: “art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” (BRASIL, 2002).

Destaca ainda que a venda de ingressos pela internet gera inúmeras vantagens e comodidades para os promotores de eventos culturais, de forma que apenas eles deveriam arcar com essas custas de vendas de ingressos online. E que ao se cobrar do consumidor esse valor o fornecedor estaria transferindo parcela considerável do risco do empreendimento. Salientou ainda o STJ que não se trataria de mera conveniência a compra pela internet, visto que ampla maioria das pessoas adquirem os ingressos pela internet ante sua maior comodidade.

E que por fim, essa cobrança ao consumidor acabaria por vulnerar o princípio da vedação à lesão enorme, previsto nos artigos 39, V e 51, IV do CDC.

5. Informativo 683 STJ - Da licitude a cobrança de uma “taxa de conveniência” pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet

Após apresentação do caso em concreto, e da análise do julgado de 2019, passo a destacar o a mudança de entendimento do julgado pela 3ª Turma do STJ mencionado no item anterior, para o do ano de 2020, que proferiu acórdão concluindo pela possibilidade de cobrança das taxas de conveniência pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet.

O novo julgado, sob a relatoria da ministra Nancy Andrigui, fundamentou sua decisão opinando pela possibilidade com o argumento de que:

Essa cobrança é lícita, desde que o consumidor seja previamente informado sobre o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque de que está pagando um valor extra a título de “taxa de conveniência”. É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa. (BRASIL, 2019).

Destaca-se que o serviço de venda de ingressos online, na forma como organizado pela empresa demandada, integra-se à cadeia e fornecimento do serviço de produção de eventos, sendo portanto, um custo repassado ao consumidor. Nesse sentido, aduz Marcio Cavalcante que:

Assim, sendo a “taxa de conveniência” um repasse de custos de intermediação, torna-se irrelevante investigar se existe, ou não, efetiva vantagem ao consumidor, pois a controvérsia se desloca para a fase pré-contratual, bastando que o consumidor seja informado prévia e adequadamente acerca dessa transferência de custos. (CAVALCANTE, 2019).

No entanto, observa o mesmo autor que deve ser:

Repelida com vigor a prática abusiva e desleal de ofertar produto/serviço por um preço artificialmente menor, para, depois de capturar a preferência do consumidor no mercado de consumo, exigir a diferença de preço sob a roupagem de um falso serviço “adicional”, aumentando indevidamente o valor a ser desembolsado pelo consumidor. (CAVALCANTE, 2019).

Sendo, essa prática além de abusiva, desleal, necessitando portanto, da informação prévia ao consumidor do custo total da compra.

6. Conclusão

Ante todo o exposto, entende-se que o STJ decidiu por modificar seu entendimento recentemente quanto a licitude da cobrança das taxas de conveniência pelo fato de o ingresso ser adquirido pela internet.

Destacamos nesse artigo ambos os pontos base em cada julgado, salienta-se a mudança de entendimento de 2019 para 2020 da 3ª Turma do STJ.

A princípio a venda de ingressos pela internet geraria diversas vantagens e comodidades para os promotores de espetáculos culturais de forma que cabe a esses a responsabilidade pelo pagamento das custas dos ingressos online. E que caso fosse repassado esse valor ao consumidor, o fornecedor estaria transferindo o risco do empreendimento.

Outrossim, em 2020 o entendimento foi alterado visto ser possível a cobrança da referida taxa de conveniência pelas empresas especializadas na venda de ingressos pela internet, no entanto a mesma precisaria apenas informar previamente ao consumidor o custo total da compra, inclusive o custo da intermediação, par assim evitar que o consumidor ser surpreendido com uma proposta de menor valor do que o efetivo, em prejuízo dos demais concorrentes que também disputam a preferência do consumidor, nos mais diversos ramos de atividade.

8. Referências

ALMEIDA, Fabrício Bolzan. Direito do Consumidor esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2020.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 23 mar. 2020.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mar. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso em: 03 mar. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.737.428/RS. Embargante: Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul – ADECONRS. Embargado: Ingresso Rápido Promoção de Eventos LTDA. Relator: Min. Nancy Andrighi. Relator do acórdão: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 06 de outubro de 2020 (Info 683). Brasília, DF: STJ, [2019]. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/686349224/recurso-especial-resp-1737428-rs-2017-0163474-2/inteiro-teor-686349243>. Acesso em: 16 mar. 2021.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É proibido que se cobre a taxa de conveniência, ou seja, um valor a mais pelo fato de o ingresso estar sendo vendido pela internet. Dizer o Direito, 2019. Disponível em: <https://www.dizerodireito.com.br/2019/05/e-proibido-que-se-cobre-taxa-de.html>. Acesso em: 03 mar. 2020.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Informativo 683-STJ comentado. Dizer o Direito, 2020. Disponível em: <https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2021/01/info-683-stj.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2020.

GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de V.; FINK, Daniel Roberto; FILOMENO, José Geraldo Brito; NERY JÚNIOR, Nelson; DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V; MIRAGEM, Bruno, Comentários ao Código de defesa do consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010.

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do direito do consumidor. Direito Material e processual. Volume único. São Paulo: Método, 2018.

CAPÍTULO 4

Operadora de plano de saúde e custeio de acompanhante de paciente idoso na internação hospitalar

Marcela France Zaidman⁴

Resumo:

O artigo busca trazer um detalhamento acerca da importância da decisão do Superior Tribunal de Justiça no que tange a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear o acompanhante do paciente idoso na internação hospitalar. Para esse fim, destaca-se a proteção do idoso na seara internacional e nacional e a imperiosa necessidade de sua proteção na seara consumerista. Analisa-se as normativas internacionais, as diretrizes constitucionais e legais no plano interno e ainda as disposições infralegais referentes ao tema. Destaca-se ainda o idoso como hipervulnerável, o qual deve ser objeto de maior proteção e atenção do direito consumerista e como a jurisprudência pátria vem tratando tal temática. Quanto a figura do acompanhante, narra-se a evolução das normativas internas e sua importância na proteção do idoso e de sua saúde. Diante de todo esse contexto, explica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.1793.840 do Rio de Janeiro, a qual tratava de recurso especial interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que entendeu improcedente o pedido de custeio pelo plano de saúde quanto às despesas com diárias do acompanhante do idoso, somente julgando parcialmente procedente o pedido no que tange aos custos do material afeto a consecução do ato cirúrgico e condenando

⁴ Especialista em Direito Público, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada.

diretamente o plano de saúde ao pagamento de tais gastos. Destaca-se ainda, da decisão do Recurso Especial pela nossa Corte Cidadã, a possibilidade de controle judicial das cláusulas dos contratos de saúde antes da vigência da Lei 9.656 de 1998 e em virtude da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Palavras-chave: Plano de saúde. Idoso. Internação hospitalar. Acompanhante. Custeio.

1. Introdução

O presente artigo tem como objetivo enunciar a necessidade de proteção do idoso em todas as searas do Direito, em especial a consumerista. Nessa senda, a decisão da nossa Corte Cidadã de que as despesas com o acompanhante do idoso devem ser custeadas pela operadora de plano de saúde deve ser objeto de destaque e de atenção, não somente em relação a evolução da temática em âmbito internacional e interno, como também das normativas legais e infralegais e das decisões jurisprudenciais.

Destaca-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi no sentido da improcedência do pedido de custeio das despesas do acompanhante do idoso pela operadora de plano de saúde, razão pela qual, tal decisão da Corte Cidadã, revela-se tão importante e objeto de análise detalhada.

Trata-se de uma importante decisão protetiva do direito dos idosos e de garantia da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do direito fundamental a saúde. Além de tratar do controle judicial e da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso nas relações contratuais anteriores a vigência da lei dos planos de saúde, Lei 9.656 de 1998.

2. A proteção do idoso na seara internacional

Na seara mundial, o panorama populacional vem apresentando grandes mudanças ao longo das últimas décadas. Há um notável declínio das taxas de natalidade e mortalidade e, consequentemente, observou-se um maior contingente de idosos, o qual foi se impondo como objeto de maior visibilidade e de necessidade de maior respeito e proteção. Segundo informações e pesquisa da Organização das Nações Unidas, na maioria dos países, o número de pessoas com 60 anos ou mais, deve duplicar até 2050.

Desse modo, as ações da sociedade a nível mundial devem possibilitar a inclusão social dos seus idosos e um maior destaque e qualidade das relações a serem estabelecidas com eles, além da sua saúde e da sua dignidade humana.

Diante desse quadro, a Organização das Nações Unidas (ONU) por sua Assembléia Geral convocou a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento em 1982, a qual produziu o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento. Esse plano de ação já falava na necessidade de proteção de consumidores idosos, além de outros aspectos como saúde, família, meio ambiente, educação e segurança de renda e emprego.

No que tange ao Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA) em seu programa das Nações Unidas para o Envelhecimento, destaca-se seu foco em facilitar e promover as três áreas de prioridade do Plano de Ação Internacional de Madrid para o Envelhecimento: pessoas idosas e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na velhice e criação de um ambiente de vida propício e favorável.

No ano de 1991, a Assembleia Geral da ONU adotou o Princípio das Nações Unidas em favor das pessoas idosas, enumerando 18 direitos a serem garantidos as pessoas idosas, entre os quais: cuidado e dignidade. Em prosseguimento, no ano de 1992, foi adotada a Proclamação do Envelhecimento e seguindo a recomendação da

Conferência, a Assembleia Geral da ONU declarou o ano de 1999 como ano internacional do idoso, sendo o dia internacional das pessoas idosas comemorado em 01 de outubro.

Em 2002, foi realizada em Madrid, a segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento e com o objetivo de desenvolver uma política internacional para o envelhecimento para o século XXI, a Assembleia adotou uma Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento de Madrid. O plano de ação pedia mudanças de atitudes políticas, práticas, legais e jurídicas para satisfação das potencialidades do envelhecimento que se traduziria no século XXI, entre as quais, destaca-se a melhora da saúde e bem estar dos idosos, assegurando pessoas, redes e ambientes de apoio.

Finalmente em 2018, foi adotada a Declaração de Viena sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas. No sistema interamericano de Direitos Humanos (Sistema ONU), destaca-se ainda o trabalho da Organização Mundial de Saúde sobre o tema.

Ao lado do sistema universal de proteção de Direitos Humanos, constituído pelos mecanismos da ONU, temos os sistemas regionais de proteção e promoção de tais direitos. No que tange ao continente americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) representa o sistema regional de Direitos Humanos.

Dessa forma, no sistema interamericanos de Direitos Humanos, os direitos fundamentais da pessoa idosa encontram-se no Protocolo de San Salvador, o qual é um protocolo adicional a Convenção Americana e que trata de direitos sociais, econômicos e culturais.

Tal diploma em seu artigo 17, traz o direito da pessoa idosa de ter especial proteção na velhice e o compromisso dos Estados-partes de adotarem, de maneira progressiva, as medidas necessárias a fim de proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada às pessoas de idade avançada que careçam dela. Finalmente, há a Convenção Interamericana sobre

a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, mas o Brasil somente o assinou, não ainda tendo ratificado e internacionalizado tal texto.

3. A proteção do idoso no direito interno

No Brasil, a Constituição de 1934 tratou explicitamente de um direito do ancião, mas apenas correlacionando-o à legislação trabalhista e ao direito previdenciário.

Já a Constituição de 1937, também relacionava o direito do idoso ao trabalho e ao seguro-velhice. A de 1946, também tratava do direito previdenciário dos idosos. Nessa mesma toada, a Constituição de 1967 com a emenda de 1969.

Foi somente com a Constituição Federal de 1988, que restaram assegurados outros direitos aos idosos e não somente os que se referiam ao trabalho e a previdência.

A nossa Carta Magna traz um título dedicado a criança, ao adolescente e ao idoso. Destaca ainda o dever concomitante da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Ainda no que tange a temática em análise, destaca-se como objetivo da República Federativa do Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Frisa-se também, na seara constitucional, a dignidade da pessoa humana, não só como sendo um dos fundamentos primordiais da República Federativa do Brasil, mas como outro pilar na imposição de práticas legais, sociais e jurídicas de respeito, promoção e proteção dos meios necessários a manutenção de uma vida digna ao idoso. Segundo Ingo Sarlet:

De todo modo especial, o princípio da dignidade da pessoa humana acaba por servir de referência inarredável no âmbito da indispensável hierarquização axiológica inerente ao processo de criação e desenvolvimento jurisprudencial do Direito. Justamente no âmbito dessa função do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se afirmar a existência não apenas de um dever de interpretação conforme a Constituição e os direitos fundamentais, mas acima de tudo, de uma hermenêutica que, para além do conhecido postulado do *in dubio pro libertati*, tenha sempre presente o imperativo segundo o qual em favor da dignidade não deve haver dúvida. (SARLET, 2005 apud FERNANDES, 2014, p. 298).

Pelo exposto, é inquestionável o fato de que na dignidade da pessoa humana estão inseridos os direitos à saúde, à vida digna, ao bem estar, à igualdade e à integridade psicofísica dos idosos.

Em prosseguimento à análise da Carta Constitucional, podemos citar ainda, de forma explícita, o direito fundamental constante do artigo 5º: a isonomia. Tal direito revela-se não só na sua vertente formal, de que os iguais devem ser tratados de forma igualitária, mas também no seu aspecto material, de que as desigualdades devem ser tratadas de forma desigual, para que possa ser alcançada a igualdade substancial. Nessa senda, dar tratamento diferenciado e prioritário aos idosos em razão de sua maior fragilidade física, de saúde e social, traduz-se como efetivação não só do direito fundamental a igualdade como do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.

Como direito social, o artigo 6º da nossa Carta Magna prevê explicitamente o direito à saúde e ainda o artigo 5º, XXXII, impõe ao Estado o dever de proteção e promoção eficiente dos direitos e

interesses dos consumidores através dos direitos fundamentais.

Na seara infraconstitucional, visando dar efetividade a todos esses mandamentos constitucionais, em 04 de janeiro de 1994, foi promulgada a Lei 8.842, a qual dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, a que buscou estabelecer a integração e maior participação dos idosos na sociedade brasileira. Como evolução legal, em 01 de outubro de 2003, foi publicada a Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso, constituindo-se como um microssistema jurídico de proteção legal dos direitos e garantias dos idosos, nas mais diversas searas, como a cível, a penal, a previdenciária, a da saúde, a habitacional, a criminal, entre outras.

4. A proteção do idoso segundo o Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, é uma legislação fundamental para regulamentar os ditames constitucionais do artigo 5º, XXXII e as relações de consumo. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social e prevalecem sobre a vontade das partes. Os direitos do consumidor são, portanto, direitos básicos, servindo de base na orientação e instrumentalização das relações consumeristas. Nessa senda, destaca-se o artigo 4º:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, **o respeito à sua dignidade, saúde** e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, **a melhoria da sua qualidade de vida**, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (grifos nossos)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; (BRASIL, 1990).

Pelo artigo supramencionado, conclui-se que o consumidor é vulnerável na relação de consumo. A vulnerabilidade advém da ordem técnica, econômica ou jurídica.

Ocorre que há grupos que necessitam de uma proteção maior, assim surgindo a figura do hipervulnerável, já reconhecida em inúmeros julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se trata da pessoa que em razão de sua condição especial – condição social, fática ou objetiva de agravamento da vulnerabilidade - ficam ainda mais expostas em razão de características pessoais ou aparentes conhecidas pelo fornecedor de atividades consumeristas.

Na figura do hipervulnerável, temos o idoso, o qual merece ser motivo de atenção ainda maior e proteção especial e diferenciada, senão vejamos:

[...] Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna. [...] (BRASIL, 2009).

[...] A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma categoria de **consumidores idosos**, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o Ministério Pú-

blico não tinha legitimidade ativa para a causa. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque pressupôs **que os idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de consumidores**, teriam capacidade cognitiva e discernimento menores do que a população em geral. Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei nº 8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da população. Idoso não é sinônimo de tolo. (BRASIL, 2018). No caso, **o direito fundamental tutelado está entre os mais importantes, qual seja, o direito à saúde. Ademais, o grupo de consumidores potencialmente lesado é formado por idosos, cuja condição de vulnerabilidade já é reconhecida na própria Constituição Federal, que dispõe no art. 230, sob o Capítulo VII do Título VIII (“Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”): “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”**

4. “A expressão ‘necessitados’ (art. 134, caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros - os miseráveis e pobres -, **os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os ido-**

sos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, ‘necessitem’ da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. Vê-se, então, que a partir da ideia tradicional da instituição forma-se, no Welfare State, um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados processualmente, isto é, adota-se uma compreensão de minus habentes impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da pessoa humana. (BRASIL, 2015a).

Além do que, no próprio artigo 4º do CDC, é notável a diretriz que estabelece a proteção da saúde, dignidade e melhoria da qualidade de vida do consumidor.

Por outro lado, infelizmente, nota-se que a saúde pública do país tem níveis, cada vez mais deficitários, o que leva a contratação de planos de saúde por grande parte da população. Como o plano de saúde presta serviços médicos e hospitalares, tendo, portanto, o papel de fornecedor na relação de consumo e o contratante sendo o consumidor, a nossa Corte Cidadã, por meio de sua súmula 608, já pacificou o entendimento segundo o qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Dessa forma, o contratante idoso de plano de saúde, é hipervulnerável na relação de consumo que detém com a operadora do plano de saúde, devendo, então, ser objeto de maior promoção e proteção de seus direitos e necessidades.

[...] Essa condição peculiar do idoso torna-o parte hipervulnerável no mercado de

planos de saúde, uma vez que apresenta grau vulnerabilidade bastante superior à do consumidor de planos de saúde em geral.

Para compensar essa hipervulnerabilidade, a Lei 9.656/1998 (art. 15), secundada pela Resolução Normativa ANS 195/2009, estatuíram normas de acentuado dirigismo contratual, que estabelecem uma solidariedade entre gerações, para proteger os usuários de plano de saúde na velhice. [...] Assim, para preservar a confiança dos contratantes no que diz respeito a esse pacto entre gerações, bem como em respeito à dignidade da pessoa idosa, é de rigor assegurar aos dependentes idosos o direito de assumirem a titularidade do plano de saúde após a morte do titular, ainda que se trate de plano coletivo por adesão. (BRASIL, 2019).

5. A figura do acompanhante do paciente idoso na legislação nacional

Não se desconhece que a figura do acompanhante é de fundamental importância na recuperação e promoção da saúde do idoso, sendo um passo primordial para que possam ser garantidos os direitos a eles assegurados pela nossa Carta Constitucional.

Nessa senda, será feito um breve compilado de tal figura na seara legal e infralegal do ordenamento jurídico pátrio.

No que tange, especificamente a lei regedora dos planos de saúde - Lei 9.656 de 1998, ela traz o seguinte mandamento:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas

nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos. (BRASIL, 1998).

Vale destacar que essa lei precede o Estatuto do Idoso, por isso não tratou especificamente da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, apesar de ter vindo posteriormente, trata-se de norma de ordem pública, de aplicação imediata, a qual não pode ser afastada.

Por outro lado, e também antes da promulgação e publicação do Estatuto do Idoso, o Ministério da Saúde, amparado pela Política Nacional do Idoso, editou a Portaria MS-GM número 280 de 1999, aduzindo que:

Art. 1º - Tornar obrigatório nos hospitais públicos, contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, a viabilização de meios que permitam a presença do acompanhante de pacientes maiores de 60 (sessenta) anos de idade, quando internados.
§ 1º - Fica autorizada ao prestador de serviços a cobrança, de acordo com as tabelas do SUS, das despesas previstas com acompanhante, cabendo ao gestor, a devida formalização desta autorização de cobrança na Autorização de Internação Hospitalar - AIH.

§ 2º - No valor da diária de acompanhante estão incluídos a acomodação adequada e o fornecimento das principais refeições. (BRASIL, 1999).

Seguindo uma ordem cronológica, temos o Estatuto do Idoso, o qual trouxe a seguinte previsão:

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. (BRASIL, 2003).

Dessa forma, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão responsável por regulamentar as relações entre operadoras e consumidores e para contribuir com ações de saúde no país, por meio das Resoluções Normativas no. 211 de 2010, no. 387 de 2015b e no. 428 de 2017, determinou, principalmente através da última resolução citada, que o que o plano hospitalar deve cobrir as despesas, incluídas alimentação e acomodação relativas ao acompanhante do idoso, a partir dos 60 anos, em atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e nos atendimentos caracterizados como de urgência ou emergência.

6. Conclusão

Revela-se de fundamental importância a acertada decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar provimento, por

maioria, ao Recurso Especial 1.793.840 oriundo do Rio de Janeiro, julgado em 15 de novembro de 2019, no qual restou condenada a operadora do plano de saúde a arcar com o pagamento das despesas referentes ao acompanhante do paciente idoso.

A população idosa vem crescendo vertiginosamente ao redor do mundo e a sociedade de forma prática, técnica e jurídica deve possibilitar a inclusão social dos seus idosos e um maior destaque e qualidade das relações a serem estabelecidas com eles, além da sua saúde e da sua dignidade humana, conforme as diretrizes de proteção dos direitos humanos dos idosos na seara onusiana e interamericana e dos preceitos do nosso ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, reconhecer o idoso como hipervulnerável na seara consumerista, merecendo ser motivo de atenção maior e proteção especial e diferenciada, revela-se de fundamental relevância.

Ainda nessa senda, garantir os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso como norma imperativa e de ordem pública, a qual não pode ser afastada, contribui para uma sociedade mais justa e solidária, além de dar garantia aos preceitos constitucionais que aduzem que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por todo o exposto, a figura do acompanhante foi também acertadamente reconhecida e m protegida como consectário lógico e legal ao direito a saúde e proteção a dignidade e bem-estar da pessoa idosa, não devendo o idoso, o qual já possui outros grandes e inúmeros gastos em função de sua condição física e social mais debilitada, arcar e se preocupar com mais essa despesa.

7. Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República,

[1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 agosto de 2020.

BRASIL. Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre Planos e seguros privados de assistência à saúde. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19656.htm. Acesso em: 25 de agosto de 2020.

BRASIL. Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2003]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 25 de agosto de 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 25 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa n. 428, de 07 de novembro 2017. Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referênciabásicaparacoberturaassistencialmínimanosplanosprivados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga as Resoluções Normativas – RN nº 387, de 28 de outubro de 2015, e RN nº 407, de 3 de junho de 2016. Brasília: ANS, 2017. Disponível em: <https://www.ans.gov.br/component/gislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzUwMg>. Acesso em: 28 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa n. 387, de 28 de outubro 2015. Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; revoga as Resoluções Normativas – RN nº 338, de 21 de outubro de 2013, RN nº 349, de 9 de maio de 2014; e da

outras providências. Brasília: ANS, 2015b. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzExMA==>. Acesso em: 28 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa n. 211, de 11 de janeiro de 2010. Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências. Brasília: ANS, 2010. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTU3NQ> Acesso em: 28 de agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n. 280, de 07 de abril de 1999. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt0280_07_04_1999.html. Acesso em: 28 de agosto de 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2a. Turma). Recurso Especial 586.316/MG. Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido: Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação – ABIA. Relator: Min. Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, 17 de abril de 2007. Brasília, DF: STJ, [2009]. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=683195&tipo=0&nreg=200301612085&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20090319&formato=PDF&salvar=false> Acesso em: 28 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (3a. Turma). Recurso Especial 1358057/PR. Recorrente: Unibanco União de Bancos Brasileiros e outros. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Min. Moura Ribeiro, 22 de maio de 2018. Brasília, DF: STJ, [2018]. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1664023&num_registro=201202620573&data=20180625&formato=PDF

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Corte Especial). Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.192.577/RS. Embargante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Embargado: Sociedade Dr. Bartholome Tacchini – Plano de Saúde Tacchimed. Relatora: Min. Laurita Vaz, 21 de outubro de 2015. Brasília, DF: STJ, [2015a]. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1430834&num_registro=201402469723&data=20151113&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em: 28 de agosto de 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4a. Turma). Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1428473/SP. Agravante: Notre Dame Intermédica S.A. Agravado: Olinda Vizzotto do Prado. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 25 de junho de 2019. Brasília, DF: STJ, [2019]. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=97676594&num_registro=201900128356&data=20190628&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 28 de agosto de 2020.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2014.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2014. (Coleção Leis Especiais para Concursos)

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Envelhecimento. Portugal: ONU, 2019. Disponível em: <https://unric.org/pt/envelhecimento/>. Acesso em: 24 de agosto de 2020.

CAPÍTULO 5

Plano de saúde e responsabilidade solidária por danos causados pelos médicos e hospitais próprios ou credenciados

Nayene Ludmila Gonçalves Sellera⁵

Resumo:

O artigo tem como finalidade fazer uma sucinta análise do julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade do plano de saúde na demora para autorização de cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital. Destaca-se que desde o ano de 2012, através do informativo 494, sobre a relatoria do Ministro Raul Araújo, o Tribunal supracitado adotou o entendimento de que o plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos causados aos associados pela sua rede credenciada de médicos e hospitais. Dessa forma, no caso de erro médico cometido por profissional credenciado, a operadora responde solidariamente, com o médico, pelos danos causados ao paciente. Assim, concluiu que o plano de saúde possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, data vênua, pode este em ação regressiva averiguar a culpa do médico ou do hospital. No caso em análise do presente artigo, tem-se que uma paciente idosa, sofreu uma queda em 2013, e foi encaminhada ao Hospital, onde realizou exames necessários. Na oportunidade foi diagnosticada com lesão grave na coluna cervical com necessidade de cirurgia de artrodese de urgência. Data vênua, em razões de entraves meramente administrativos, sem apresentação de qualquer justificativa plausível, a cirurgia foi realizada 22 (vinte e dois) dias após sua admissão no

⁵ Pós graduanda em Direitos Humanos pela Faculdade UniAmérica, pós graduanda em Direito Civil e Consumidor pela Faculdade UniAmérica, pós graduanda em Processo Civil pela faculdade UniAmérica, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, advogada.

hospital. Como resultado, o estado da paciente, que já era idosa e possuía outras enfermidades, evoluiu para um quadro de choque que desencadeou em seu óbito. Neste contexto, os familiares da paciente ajuizaram ação de indenização contra a operadora do plano de saúde. O Tribunal de Justiça local então julgou procedente o pedido, sobre o fundamento de que o óbito ocorreu em razão da demora da cirurgia, através de laudos periciais realizados. Inconformados com a sentença arbitrada, a operadora de plano de saúde interpôs recurso especial e alegou que no caso em questão, não caberia responsabilização solidária com o hospital. Ao receber o recurso especial, o STJ acertadamente concluiu que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado sem justificativa, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora de plano de saúde, resultando na sua responsabilização. Ademais, reiterou que a operadora de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, tanto por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

Palavras-chave: Plano de saúde. Responsabilidade solidária plano de saúde. Demora de cirurgia. Defeito na prestação de serviço.

1. Introdução

O intuito deste artigo é fazer uma breve análise de um julgado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a relatoria do ministro Raul Araújo, realizado no dia 11/02/2020; acerca da responsabilidade da operadora de plano de saúde em caso de demora injustificada para autorização de cirurgia.

O julgado em tese, trata do caso de uma idosa, com uma série de enfermidades, que ao sofrer uma queda, foi encaminhada para um hospital. Realizou exames que se fizeram necessários, e de pronto foi

diagnosticada com lesão grave na coluna cervical. Na oportunidade, como tratamento urgente, foi indicada para realizar uma cirurgia de artrodese de urgência. Ocorre que, sem qualquer justificativa plausível, por entraves meramente administrativos, a cirurgia só ocorreu 22 (vinte e dois) dias depois. Em contrapartida, diante da demora, a paciente entrou em um quadro de choque que levou ao seu óbito.

Diante do exposto, os familiares ingressaram com uma ação contra a operadora de plano de saúde, na qual foi julgada procedente no Tribunal local, entendendo que houve falha na prestação de serviço desta.

Inconformada com a decisão supracitada, a operadora do plano de saúde, resolveu interpor recurso especial ao STJ, sobre o fundamento de que não há que se falar em responsabilização solidária com o hospital e que há ausência de responsabilidade no caso de erro médico por um de seus hospitais ou médicos credenciados.

No julgamento do caso, o STJ, foi esclarecido dois pontos principais, quais sejam: a demora para autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização; e reiterou que a operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, quando presta esse serviço tanto por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

2. Plano de saúde - conceito e relação consumerista

A saúde é um direito taxativamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal. “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência

aos desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 1988).

A priori é meritório destacar que o entendimento da maioria dos doutrinadores constitucionais, é de que os direitos elencados no artigo acima, estão devidamente protegidos de supressão ou alteração através de emenda constitucional, vez que são cláusulas pétreas.

Assim, tem-se que embora seja um direito essencial de cunho constitucional, e em que pese ainda não tenha sido declarado o estado de coisa inconstitucional da saúde no Brasil pelos Tribunais Superiores, ou seja, ainda não houve uma manifestação de que há no sistema, segundo palavras do Ministro Marco Aurélio de Melo:

[...] uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de pluralidade de autoridades (BRASIL, 2015).

É notório que o país, não possui uma estrutura eficiente para atender com excelência todos os pacientes que necessitam o amparo médico.

Conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 47.039.728 (quarenta e sete milhões trinta e nove mil setecentos e vinte e oito) brasileiros são beneficiários de plano de saúde privado, até dezembro de 2019 (BRASIL, 2020).

O Plano de saúde, que vem crescendo gradativamente, é um serviço realizado por operadoras, empresas privadas, cujo objetivo é realizar assistência médica e hospitalar. Segundo a Lei 9656, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, Plano Privado de Assistência, o Plano Privado de Assistência a Saúde é:

[...] prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (BRASIL, 1998).

Em linhas gerais, o plano de saúde é um seguro em que empresas privadas, mediante pagamento oferecem serviços médicos e hospitalares. Importante destacar que este tipo de relação é regido pelo direito do consumidor – já que é fundado em prestações de serviços médicos e hospitalares. Devendo por tanto qualquer divergência ser analisada à luz do CDC.

O Código de defesa do consumidor, define consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (BRASIL, 1990).

Ademais, define também o fornecedor:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (BRASIL, 1990).

Diante do exposto, não há dúvidas de que pessoa que contrata um plano de saúde, enquadra-se como consumidora, vez que esta adquire o seguro e é a pessoa exclusiva que possui destinação do pleito. E a operadora de plano de saúde fornecedora de prestação de serviços, quais sejam médicos e hospitalares.

É o que entende o STJ, conforme súmula a seguir: “Sumúla 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (BRASIL, 2018)

Importante destacar aqui que a ressalva apresentada na súmula citada, refere-se a contratos em que os usuários participam da gestão do plano, e não há objetivo de auferir lucros, além de ser ofertado a um grupo restrito.

3. Caso concreto

O julgado em análise trate-se de uma paciente, idosa, com uma série de enfermidades que possuía plano de saúde junto à Central Nacional Unimed Cooperativa Central, e sofreu uma queda no dia

20/05/2013. Na ocasião, foi encaminhada ao Hospital Unimed de Guarulhos. Importante destacar que este hospital é credenciado pelo plano de saúde da paciente.

No seu atendimento foi diagnosticada com lesão grave na coluna cervical, e foi indicada com urgência para realizar cirurgia de artrodeese.

Ocorre que, sem nenhuma justificativa plausível, em razão de entraves administrativos para a realização da cirurgia, esta só foi realizada após 22 (vinte e dois dias) após a sua admissão no hospital, em 12/06/2013.

Como resultado, o estado da paciente evoluiu para um quadro de choque que culminou em seu óbito no dia seguinte à realização da cirurgia, em 13/06/2013.

Inconformados com a falha na prestação de serviços, seus familiares ingressaram com ação contra o plano de saúde, que foi julgado procedente pelo Tribunal a quo consignado, que através de laudos periciais, ficou caracterizado o nexo causal entre a demora na prestação do serviço hospitalar e o seu falecimento.

Conforme explanado no tópico anterior, ficou claro que a responsabilidade dos planos de saúde deve ser avaliada na ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de uma relação consumerista; já que é contrato fundado em prestações de serviço; existe uma responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.

A operadora de plano de saúde, na condição de prestadora de serviço responde perante o consumidor pelos defeitos e falhas apresentados.

Esse entendimento vai diretamente de encontro ao CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. (BRASIL, 1990).

A responsabilidade das operadoras de planos de saúde advém justamente da falha de prestação do serviço contratado pelo consumidor, qual seja a prestação de serviços médicos e hospitalares. A responsabilidade desta, além de possuir previsão no CDC, encontra fundamentação no Código Civil:

Art. 932 São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; [...]
(BRASIL, 2002).

Ademais, desde o ano de 2012, através do informativo 494, sobre a relatoria do Ministro Raul Araújo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos causados aos associados pela sua rede credenciada de médicos e hospitais. Dessa forma, no caso de erro médico cometido por profissional credenciado, a operadora responde solidariamente, com o médico, pelos danos causados ao paciente. Assim, concluiu que o plano de saúde possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, data vênua, pode este em ação regressiva averiguar a culpa do médico ou do hospital.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE.

HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela prestação do serviço.

A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com

trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal.

A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.

Agravo interno a que se nega provimento. (BRASIL, 2020).

Ocorre, que insatisfeita com o julgamento procedente do tribunal local, a operadora de saúde, Central Nacional Unimed Cooperativa Central, interpôs recurso especial ao STJ, no intuito de ter a sentença reavaliada.

Alegou na peça processual, que não o plano de saúde não deve ser solidariamente responsável pelo hospital pela paciente, porque “limitou-se a prestar serviço de cobertura de plano de saúde, simplesmente emitindo autorização e custeando-o, sem qualquer negativa”. Como outro fundamento, justificou que trataria de erro médico praticado no âmbito das relações de autorizações de procedimentos, uma vez que não houve nenhum defeito no serviço entre a operadora. Frisou que a solidariedade não se presume, e alegou que “a operadora de plano de saúde em nada contribui para a má prestação dos serviços médicos realizados pelos profissionais médicos”.

Ao julgar o caso, o STJ constatou que tendo em vista laudo pericial constando que o óbito se deu em razão da demora da prestação do serviço, ocorreu a falha na prestação de serviço.

Na ocasião destacou os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO Documento: 104798327 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 4 de 6 Superior Tribunal de Justiça ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SÚMULA 83/STJ. 2. QUINHÃO CABÍVEL AOS DEVEDORES. 50%. O CREDOR PODE EFETUAR A COBRANÇA INTEGRAL EM RELAÇÃO A QUALQUER UM DELES. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que concerne à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que “Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012). 2. No que se refere ao quinhão que caberia a cada devedor, em se tratando de responsabilidade solidária, mostra-se cabível no percentual de 50% para cada um,

ressalvado previsão em contrato. Ademais, não se mostra imperativa a discussão acerca do grau de responsabilidade dos co-devedores, na medida em que, na responsabilidade solidária, todos os devedores respondem cada qual pela sua dívida, tendo o credor o direito de efetuar a cobrança integral da dívida em relação a qualquer um deles, podendo, inclusive, ser apresentado contra o outro ação de regresso para reaver o valor excedente à cota parte por ele paga. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL, 2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO DE DIAGNÓSTICO FORNECIDO PRO LABORATÓRIO CREDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO 1. Evidenciado que o erro na análise de material colhido para exame por parte do laboratório réu provocou o diagnóstico equivocado de presença de tumor maligno e fez com que a parte autora fosse submetida desnecessariamente a procedimento cirúrgico, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço apta a caracterizar ato ilícito passível de causar abalo de ordem moral e a consequente indenização 2. “Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço”. (REsp 866371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Documento: 104798327 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 5 de 6 Superior Tribunal de Justiça 3. A operadora do plano responde perante o consumidor, solidariamente, pelos defeitos na prestação de serviços médicos e de diagnóstico, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados (hipótese dos autos), nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo regimental desprovido. (BRASIL, 2014).

O STJ acertadamente concluiu que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado sem justificativa, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora de plano de saúde, resultando na sua responsabilização. Ademais, reiterou que a operadora de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, tanto por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

Eis a certidão:

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente) e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. (BRASIL, 2020).

4. Conclusão

Verifica-se que o STJ apresentou uma decisão completamente acertada no presente julgado. O contrato de plano de saúde trata-se de uma relação entre consumidor (beneficiário) e o fornecedor de prestação de serviços médicos e hospitalares (operadora de plano de seguro) Dessa forma, deve-se observar as normas consumeristas, que de forma clara aduz que em caso de falha na prestação de serviços, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária.

A demora para autorização da cirurgia ressaltada como urgente, por entraves administrativos sem qualquer justificativa plausível, demonstra a falha na prestação de serviço da operadora de plano de saúde, configurando a sua responsabilidade. O fato de não prestar o serviço de forma eficiente, da forma esperada pelo consumidor, já configura defeito no serviço. A consumidora realizou contrato de prestação com a operadora de saúde e espera que o serviço. Dessa forma espera que o serviço contrato será executado de forma satisfatória. Dessa forma, esta tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, tanto por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

Para finalizar, tem-se a ementa do caso:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
1.414.776 - SP (2018/0329235-

7) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL ADVOGADO : MARCIO
ANTONIO EBRAM VILELA E OUTRO(S) - SP112922
ADVOGADOS : THIEMY CURSINO DE MOURA
HIRYE QUERIDO - SP260550 LUCAS ADAMIVILELA

- SP331465 AGRAVADO : JOSE VIGOLVINO FILHO
AGRAVADO : JOSE CLAUDIO VIGOLVINO COSTA
AGRAVADO : PATRICIA CLAUDIA DA COSTA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
SARA FERREIRA DE OLIVEIRA - SP339927 INTERES.
: UNIMED DE GUARULHOS- COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS : JOÃO
FRANCISCO

JUNQUEIRA E SILVA - SP247027 JANAINA
BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA -
SP203510 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA
AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA.
ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO
DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL
ENTRE CONDUTA E

RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código

Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. Documento: 104798322 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 04/03/2020 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (BRASIL, 2020).

Lado outro, a operadora de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, tanto por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

O consumidor, tendo em vista ser beneficiário do contrato

de prestação de serviços não deve ser em nenhuma hipótese ser prejudicado com a falha de prestação de serviços, independentemente de ser médico contratado ou credenciado. A garantia de que o médico será qualificado deve ser do plano e do hospital. Em caso de erro, deve ser avaliado a possibilidade em ação regressiva da operadora do plano de saúde em relação ao profissional. Não sendo ônus do consumidor verificar a competência dos serviços oferecido por este.

5. Referências

BEIJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 23 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre Planos e seguros privados de assistência à saúde. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19656.htm. Acesso em: 19 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 13 ago. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sala de situação. Brasília: ANS, 2020a. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de>

-situacao. Acesso em: 23 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Seção). Súmula n. 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Brasília, DF: STJ, [2018]. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=\(sumula%20adj1%20%27608%27\).#TIT1TEMA0](https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27608%27).#TIT1TEMA0) Acesso em: 19 ago.2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4.Turma). Agravo Interno em Recurso Especial 0270126-4/SP. Agravante: Aparecida Tatiana Andrade Queiroz. Agravado: Unimed do ABC - Cooperativa de trabalho médico. Relator: Min. Raul Araújo, 23 de março de 2012. Brasília: STJ, [2020]. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/857284749/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1581973-sp-2019-0270126-4/inteiro-teor-857284759> Acesso em: 11 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4.Turma). Agravo Regimental em Recurso Especial 1.414.776/SP. Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Agravado: Jose Vigolvino Filho. Relator: Min. Raul Araujo, 16 de dezembro de 2019. Brasília: STJ, [2019]. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/882001394/agravo-em-recurso-especial-aresp-1414776-sp-2018-0329235-7>. Acesso em: 20 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3.Turma). Agravo Regimental em Recurso Especial 1.635.254/SP. Agravante: Burigotto S.A. Indústria e Comércio. Agravado: Benitez Moura da Rocha Filho. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 21 de março de 2017. Brasília: STJ, [2017]. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_AGINT-RESP_1635254_3db1a.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAD4VJ344N&Expires=1616066582&Signature=P-2ZOz%2BiUm00zQGZ%2F2ySFy8G2qJI%3D. Acesso em: 20 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347. Requerente: Parti-

do Socialismo e Liberdade – PSOL. Requerido: União. Relator: Min. Marco Aurélio, 18 de março de 2020. Brasília: STJ, [2020]. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560>. Acesso em: 24 ago. 2020.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. (Coleção Leis Especiais para Concursos).

CAPÍTULO 6

A responsabilidade objetiva em face da ausência de prévia informação

Rogério de Cássio Neves Ferreira Filho⁶

Resumo:

O presente artigo tem como finalidade fazer uma sucinta análise do julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade pelo fato do produto. Iremos partir do caso concreto do julgamento do Recurso Especial nº 1.774.372, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O referido caso, relata se um laboratório tem responsabilidade objetiva na ausência de prévia informação qualificada quantos aos possíveis efeitos colaterais da medicação, ainda que se trate do chamado risco de desenvolvimento. Primeiramente o estudo analisará a responsabilidade objetiva no CDC, depois o princípio da informação e a teoria do desenvolvimento. Por fim, deve-se analisar o caso concreto e a respectiva conclusão.

Palavras-chave: Responsabilidade objetiva. Princípio da informação. Teoria do desenvolvimento. Responsabilidade pelo fato do produto.

1. Introdução

O intuito deste artigo é fazer uma breve análise de um julgado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a relatoria da ministra

⁶ Pós graduando em Direitos Humanos pela Faculdade UniAmérica, pós graduado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduado em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, advogado.

Nancy Andrichi, julgado em 05/05/2020; acerca da responsabilidade pelo fato do produto, se o laboratório tem responsabilidade objetiva na ausência de prévia informação qualificada quantos aos possíveis efeitos colaterais da medicação, ainda que se trate do chamado risco de desenvolvimento.

O julgado em tese, trata do caso de um laboratório farmacêutico Boheringer fabrica, que comercializa o medicamento Sifrol, indicado para tratamento da doença de Parkson. Maria fez uso do medicamento e, segundo alega, isso lhe causou, como efeito colateral, um transtorno mental chamado “jogo patológico” (F63.0), mais popularmente conhecido como “vício em jogar”. Essa compulsão desenvolvida resultou na dilapidação de seu patrimônio. Diante disso, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o fabricante. Vale ressaltar que existem diversos estudos científicos que demonstram a possível relação do uso deste medicamento e o desenvolvimento do transtorno de “jogo patológico”. Há, inclusive, um alerta da ANVISA a esse respeito.

A ação foi julgada improcedente em 1º grau, mas o TJ/RS deu parcial provimento à apelação da autora, fixando culpa concorrente entre ela e o laboratório, e concedendo dano moral de R\$ 20 mil.

A relatora dos recursos interpostos, ministra Nancy Andrichi, de início lamentou profundamente que a vítima, parte no processo, não tenha podido ver seu processo julgado em vida. Ao tratar da responsabilidade civil do laboratório, S. Exa. ponderou que a OMS classifica o jogo patológico como doença e no CID 10 a patologia está inserida no capítulo dos transtornos mentais.

No julgamento do caso, o STJ, esclareceu pontos importantes, mas antes de analisarmos o caso concreto deve-se observar a responsabilidade objetiva do cdc, o direito a informação e a teoria do risco do desenvolvimento. Sendo de suma importância o presente artigo.

2. Da responsabilidade objetiva no CDC

Sabe-se que a responsabilidade civil se fulcra na culpa em sentido lato – dolo ou culpa strictu sensu – do agente que responde.

Mas, o ordenamento jurídico brasileiro conhece a chamada responsabilidade objetiva, que é uma exceção a responsabilidade via a prova da culpa.

Observe-se a leitura do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos ocasionados por seus agentes. A isso se some a redação do artigo 21, XXIII, letra c, da Constituição que trata da responsabilidade por danos nucleares.

Observe-se que a relação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor não é taxativa. De forma exemplificativa, tem-se: princípio da precaução; princípio da dimensão coletiva; princípio da boa-fé, princípio da boa-fé objetiva; princípio da proteção (incolumidade física, incolumidade psíquica, incolumidade econômica); princípio da confiança; princípio da transparência.

O Código de Defesa do Consumidor afora a situação dos profissionais liberais criou a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Veja-se a redação do artigo 14, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (BRASIL, 1990).

Mas, no artigo 12 do CDC é dito que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor” (BRASIL, 1990). Trata-se de nítido exemplo de responsabilidade objetiva, onde não há exigência da prova de culpa, bastando a relação de causa e efeito.

O próprio artigo 14 do CDC diz que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (BRASIL, 1990).

Nesse sentido Cláudia Lima Marques:

Conforme os supracitados dispositivos, a regra nas relações de consumo é a responsabilidade objetiva, não havendo a necessidade do consumidor provar a culpa do fornecedor. A obrigação do fornecedor em ressarcir os danos sofridos pelo consumidor aparece como consequência do nexo causal entre o

proceder do agente e o dano resultante. Este é um ônus que o fornecedor de serviços ou produtos têm que aceitar para que possa desenvolver atividades de risco (MARQUES, 2003, p. 16).

É nítido que o artigo 14 do CDC adotou a ideia de responsabilidade sem culpa ou objetiva.

Mas a leitura do artigo 12, parágrafo terceiro, III, e 14, parágrafo terceiro, II, do CDC nos permite ainda concluir que se houver prova de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro, não há responsabilidade do fornecedor que sustente o efeito ressarcitório.

Assim se o consumidor ou o terceiro agiram com culpa, só há exclusão da responsabilidade se ela, a culpa, for unicamente deles. Se for concorrente, se mantém a responsabilidade não por ser objetiva, mas porque o fornecedor também agiu com culpa. Será necessário, nessa hipótese, fazer-se uma pesquisa da conduta culposa do fornecedor.

Sendo assim, a adoção da Responsabilidade Civil Objetiva faz com que o Direito do Consumidor volte-se para a vítima, protegendo-a com sua legislação. O Código de Defesa do Consumidor é embasado no sentimento de Justiça, estabelecendo que o industrial deve arcar com seus custos e danos, já que este é o beneficiado com o produto.

3. Direito a informação

O direito básico de informação constitui importante ferramenta de equilíbrio entre as partes na relação de consumo, possibilitando ao consumidor a escolha consciente dos produtos ou serviços disponíveis no mercado, na medida em que anula, em tese, a sua vulnerabilidade informacional.

É necessário frisar a importância da informação de acordo com o jurista Luís Gustavo Grandinetti de Carvalho, em que explica

importantíssimo pensamento a respeito da informação:

Não há sociedade sem comunicação de informação. A história do homem é a história da luta entre ideias, é o caminhar dos pensamentos. O pensar e o transmitir o pensamento são tão vitais para o homem como a liberdade física (CARVALHO, 2020, p. 256).

Em uma sociedade moderna, globalizada e da mais alta velocidade de comunicação, a informação clara, precisa, adequada e correta é um dever de qualquer fornecedor a seu consumidor.

A defesa e garantia dos direitos do consumidor, enraizada desde a CF em seus artigos 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, sendo fortalecida pelo CDC no ano de 1990, ainda não tem em plenitude seu funcionamento. Na verdade ainda estamos longe disso. O CDC, em seus primeiros artigos, trouxe muitos direitos que são dados ao consumidor. Verdadeiros princípios que deveriam ser usados em todas as relações entre fornecedor e consumidor, mas que a nossa realidade e os processos judiciais mostram uma situação diversa.

Um dos princípios mais vilipendiados, por incrível que pareça, é o princípio da informação. Diz o artigo 6º do CDC, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (BRASIL, 1990).

Em uma relação em que o que mais pesa é o desequilíbrio entre fornecedor e consumidor, o direito à informação é o caminho mais

rápido para tornar esse acordo algo equilibrado e justo para ambas as partes.

É importante se apresentar a seguinte questão: o direito à informação não se liga com uma apresentação de qualidades menores dos produtos e serviços. O direito à informação se liga puramente a relação de boa-fé entre as partes, ou seja, a existência de uma negociação verdadeira e honesta. Ele se liga ao fato de em uma negociação apresentar todas as informações contratuais, de forma clara e que torne o consumidor ciente de tudo que pode acontecer no decorrer da prestação do serviço ou da garantia de um produto, por exemplo.

Um interessante caso exemplo visto recentemente foi a decisão do STJ, pelo entendimento de sua 3ª Turma, que condenou um hospital e um plano de saúde por não informar corretamente a consumidora do descredenciamento do estabelecimento dos quadros do plano de saúde. Segundo o Tribunal, a troca deve ser informada anteriormente ao consumidor do plano, evitando uma surpresa e um despreparo em casos emergenciais, como ocorreu. No caso concreto ainda houve o agravante de ser uma situação de saúde, tornando mais delicada a situação.

Tendo isso em vista, a relatora, ministra Nancy Andrigli, teceu comentários muito interessantes sobre a necessidade de se ater aos princípios do direito consumerista para o equilíbrio contratual:

Esses requisitos estabelecidos por lei servem para garantir a adequada e eficiente prestação de serviços de saúde, de modo a evitar surpresas e interrupções indevidas de tratamentos médico-hospitalares em prejuízo do consumidor. Os princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação, devem ser observados pelos fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos

aqueles que, para o consumidor, participem da cadeia de fornecimento”, afirmou a ministra, em voto seguido por unanimidade. (BRASIL, 2018).

Portanto, quando se trata de uma relação consumerista, toda informação, que torne mais clara, mais correta e mais transparente a relação entre fornecedor e consumidor, é pouca. Afinal, no atual estágio da sociedade brasileira, não cabe mais tentar o “jeitinho brasileiro” sobre qualquer um. O direito está aí para tentar, ao máximo, defender e reequilibrar aqueles que se sentem prejudicados por mas informações sobre produtos e serviços

4. Da teoria do risco do desenvolvimento

O risco do desenvolvimento consiste no fato de que os riscos advindos da introdução de um produto no mercado não serem conhecidos ou identificados prontamente, só sendo conhecidos depois, por um desenvolvimento tecnológico não existente na época em que o mesmo foi inserido no mercado.

Nesse sentido, Marcelo Junqueira Calixto:

Os riscos do desenvolvimento são aqueles riscos não cognoscíveis pelo mais avançado estado da ciência e da técnica no momento da introdução do produto no mercado de consumo e que só vêm a ser descobertos após um período de uso do produto, em decorrência do avanço dos estudos científicos (CALIXTO, 2016 apud TARTUCE, 2016, p. 532-533).

Ainda, segundo James Marins:

Risco do desenvolvimento é a possibilidade de que um determinado produto venha a ser introduzido no mercado sem que possua defeito cognoscível, ainda que exaustivamente testado, ante o grau de conhecimento científico disponível à época de sua introdução, ocorrendo, todavia que, posteriormente, decorrido determinado período do início de sua circulação no mercado de consumo venha a se detectar defeito, somente identificável ante a evolução dos meios técnicos e científicos, capaz de causar danos aos consumidores (MARINS, 1993, p. 128).

Há uma pequena parcela dos doutrinadores, que entende o risco do desenvolvimento como excludente de responsabilidade.

Rui Stoco, defensor deste entendimento, conclui:

Do que se conclui que o legislador reconheceu a possibilidade de o produto, após desenvolvido e introduzido no mercado de consumo, apresentar perigo para o consumidor. Não obstante isso, preferiu não responsabilizar pelo risco do desenvolvimento, mas apenas impor a comunicação às autoridades e consumidor através de anúncios (STOCO, 2012 apud POLICARPO, 2012, p. 2).

Mas como dito, esse é o posicionamento minoritário e não adotado pelo ordenamento jurídico pátrio vigente.

A corrente majoritária defende a responsabilização do fornecedor. Se assim não o fosse, nos depararíamos com a possibilidade de responsabilizar a vítima por dano ocorrido pela responsabilidade do fornecedor.

Ou seja, não se mostra justo um consumidor vitimado por um

acidente de consumo, deixar de ser indenizado.

5. Caso concreto

O julgado em análise trata-se do laboratório farmacêutico Boheringer que fabrica e comercializa o medicamento Sifrol, indicado para tratamento da doença de Parkson. Maria fez uso do medicamento e, segundo alega, isso lhe causou, como efeito colateral, um transtorno mental chamado “jogo patológico” (F63.0), mais popularmente conhecido como “vício em jogar”. Essa compulsão desenvolvida resultou na dilapidação de seu patrimônio. Diante disso, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o fabricante. Vale ressaltar que existem diversos estudos científicos que demonstram a possível relação do uso deste medicamento e o desenvolvimento do transtorno de “jogo patológico”. Há, inclusive, um alerta da ANVISA a esse respeito.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.774.372, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou em parte acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para majorar a indenização a ser paga ao espólio de uma paciente que desenvolveu o chamado “jogo patológico” ao usar remédio para tratamento da doença de Parkinson. Este efeito colateral não constava da bula do medicamento à época.

Segundo consta nos autos, a mulher – que faleceu no curso do processo – foi diagnosticada com a doença em 1997 e passou a usar o medicamento Sifrol, cuja dose foi aumentada por recomendação médica em dezembro de 1999. No período de julho de 2001 a setembro de 2003, ela perdeu mais de R\$ 1 milhão. A compulsão terminou tão logo o uso contínuo do medicamento foi suspenso.

O TJRS condenou o laboratório fabricante a pagar danos morais e 45% da perda patrimonial, pois reconheceu a culpa concorrente da paciente por ter utilizado o remédio em dosagem maior do que a

recomendada. Ambas as partes recorreram.

A relatora para os recursos no STJ, ministra Nancy Andrichi, ressaltou em seu voto que o caso deve ser resolvido com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois diz respeito a acidente de consumo, na modalidade fato do produto, uma vez que o medicamento não teria oferecido a segurança legitimamente esperada pelo usuário, em virtude da falta de informações sobre os riscos.

No caso de medicamentos, continuou a ministra, o fabricante tem o dever de informar sobre o risco inerente ao seu uso, como previsto no art. 9º do CDC – cuja violação caracteriza defeito do produto e gera a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo dano causado.

Segundo a relatora, ficou comprovado no processo que o jogo patológico – doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – foi efeito colateral do medicamento e que tal risco não constava da bula naquela época (atualmente, a bula alerta sobre essa possibilidade).

Para ela, a responsabilidade da empresa não pode ser afastada sob a alegação de se tratar de risco inerente ao desenvolvimento do produto, o qual não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação. Afinal, o defeito já era existente desde o momento da concepção do produto, “embora não perceptível *a priori*, caracterizando, pois, hipótese de fortuito interno.

Nesse sentido, segundo a ministra Nancy Andrichi:

O risco inerente ao medicamento impõe ao fabricante um dever de informar qualificado (art. 9º do CDC), cuja violação está prevista no § 1º, II, do art. 12 do CDC como hipótese de defeito do produto, que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente. O ordenamento jurídico não exige que os medicamentos sejam fabricados com garantia de segurança absoluta,

até porque se trata de uma atividade de risco permitido, mas exige que garantam a segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba as informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8º do CDC). O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele. O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito interno. (BRASIL, 2020).

Ao afastar a culpa concorrente, a ministra determinou o pagamento integral dos danos materiais. Levando em conta que a vítima tinha doença de Parkinson e que, por causa da compulsão, deixou de trabalhar como advogada quando já estava com mais de 50 anos, “fase de maior dificuldade de retorno ao mercado de trabalho”, a ministra aumentou o valor dos danos morais de R\$ 20 mil para R\$ 30 mil.

Os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a relatora.

O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais

ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele.

Conforme explica Sérgio Cavalieri Filho:

O dever de informar, portanto, pode também ser fundamento da responsabilidade do fornecedor, cuja violação pode levá-lo a ter que responder pelos riscos inerentes, porém desconhecidos da sociedade de consumo; nesse caso, a responsabilidade não tem por fundamento um defeito de segurança do produto ou do serviço, mas o defeito de informação ou de comercialização, que envolve a apresentação, a publicidade e a informação adequada acerca da sua nocividade ou periculosidade. É por isso, por exemplo, que determinados medicamentos devem indicar na embalagem ou na bula todos os efeitos colaterais que podem causar, e só podem ser vendidos com prescrição médica. (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 613).

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade do laboratório por medicamento fabricado e comercializado, com exclusividade, que teria causado ao paciente o quadro compulsivo e incontrolável conhecido como jogo patológico, o qual, por sua vez, acarretou-lhe a dilapidação de todo o seu patrimônio.

Cabe ressaltar, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois revela, em princípio, típica hipótese de acidente de consumo, mais especificamente de fato do produto, considerando a

alegação de que o medicamento fabricado pelo laboratório não teria oferecido a segurança que dele legitimamente se podia esperar, em virtude da falta de esclarecimentos sobre os riscos relacionados ao seu uso, em especial, sobre o jogo patológico.

Não se desconhece que todo medicamento traz em si, em maior ou menor grau, riscos à saúde ou à segurança do consumidor, intrínsecos à sua essência, mas que são razoavelmente aceitos diante dos benefícios esperados.

Esse risco inerente ao produto comercializado impõe, em contrapartida, um dever de informar qualificado, exigindo o art. 9º do CDC que o fornecedor preste esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso. A violação desse dever de informar qualificado está prevista no § 1º, II, do art. 12 do CDC como hipótese de defeito do produto, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente (BRASIL, 1990).

Assim, o fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto, se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que viessem a ocorrer em função dele.

Por sua vez, o risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando hipótese de fortuito interno.

O desconhecimento quanto à possibilidade de desenvolvimento do jogo patológico como reação adversa ao uso do medicamento subtraiu do paciente a capacidade de relacionar, de imediato, o

transtorno mental e comportamental de controle do impulso ao tratamento médico ao qual estava sendo submetido, sobretudo por se tratar de um efeito absolutamente anormal e imprevisível para o consumidor leigo e desinformado.

6. Conclusão

Verifica-se que o STJ apresentou uma decisão completamente acertada no presente julgado. No ano em que a autora começou a fazer uso do Sifrol, na bula do remédio não mencionava a possibilidade de o uso do medicamento causar dependência compulsiva por jogos. Essa informação só veio a ser acrescentada tempos depois. Logo, houve defeito do produto por não informar na bula os possíveis efeitos colaterais da medicação que a autora estava utilizando, o que só veio a ocorrer posteriormente.

Deve-se observar que um dos argumentos do laboratório, o qual não foi aceito, era o de que não haveria dever de indenizar em razão da aplicação da teoria do risco do desenvolvimento (entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação). Decisão acertada, pois o risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori. Trata-se, portanto, de hipótese de fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor não incluiu os riscos de desenvolvimento entre as causas exonerativas da responsabilidade do fornecedor, riscos estes que nada mais são do que espécies do gênero defeito de concepção.

Esse risco exige um dever especial de informação. Como os medicamentos apresentam esse risco inerente (são produtos potencialmente perigosos), o fornecedor possui um dever de

informar qualificado. Isso significa que o fornecedor deverá prestar esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da sua nocividade ou periculosidade, conforme artigos 9º e 12º do CDC.

Por fim, é válido ressaltar que a responsabilização do fornecedor por acidente do produto não basta ficar evidenciado que os danos foram causados pelo medicamento. É necessário que fique demonstrado que o produto era defeituoso. O que ficou completamente caracterizado no caso concreto.

7. Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 set. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 13 set. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso em: 21 set. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial 1.774.372/RS. Recorrente: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica LTDA e Maria Amélia Souza da Rocha - Espólio. Recorrido: Os mesmos. Relatora: Min. Nancy Andrichi, 05 de maio de 2020. Brasília: STJ, [2020]. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=109369306&num_registro=201802726913&data=20200518&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 21 set. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso

Especial 1.725.092/SP. Recorrente: Fundação Antônio Prudente e Unimed Paulistana Soc Cooperativa de Trabalho Médico - Em liquidação extrajudicial. Recorrido: Juliana Franzim Huneke. Relator: Min. Nancy Andrighi, 20 de março de 2018. Brasília: STJ, [2018]. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1691388&num_registro=201700590272&data=20180323&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em: 22 set. 2020.

CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. A informação como bem de consumo. *Revista Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 41, p. 251-256, jan./mar. 2020.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MARINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto: os acidentes de consumo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

POLICARPO, Nathália Sant'Ana. O risco do desenvolvimento e a responsabilidade do fornecedor. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n. 106, nov. 2012. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12402&revista_caderno=10. Acesso em: 10 set. 2020.

